

犯罪通论笔记 (2025 秋)

Peking University

雨落潇潇

2025 · 12 · 08

目录

I	正文	1
1	犯罪导论	2
1.1	犯罪镜像	2
1.1.1	生活事实中的犯罪多面相	2
1.1.2	犯罪学视角的犯罪镜像	2
1.1.3	刑法学视角的犯罪镜像	2
1.1.4	犯罪的界定	2
1.2	犯罪类型	2
1.2.1	自然犯 v. 法定犯	2
1.2.2	重罪 v. 轻罪 v. 微罪（违警罪）	3
1.2.3	故意犯 v. 过失犯	3
1.2.4	作为犯 v. 不作为犯	3
1.2.5	实害犯 v. 危险犯	4
1.2.6	一般犯 v. 特别犯	4
1.2.7	政治犯 v. 刑事犯	4
1.3	犯罪原因	5
1.3.1	古典学派的自由意志论	5
1.3.2	犯罪人类学的解释	5
1.3.3	犯罪社会学的解释	5
1.3.4	犯罪心理学的解释	6
1.3.5	犯罪经济学的解释	6
1.3.6	马克思主义犯罪学的解释	6
1.3.7	综合原因论的解释	7
1.3.8	被害人学的新思维?	7
1.4	犯罪趋势	7
1.5	犯罪对策	7

2	刑罚导论	8
2.1	概念与特征	8
2.1.1	刑罚与非刑罚正式制裁	8
2.1.2	刑罚与非正式制裁	8
2.1.3	犯罪前科制度与犯罪附随后果	8
2.2	结构与种类	8
2.2.1	刑罚结构	8
2.2.2	刑罚变迁——从野蛮到文明	8
2.2.3	死刑的中国命运	9
2.2.4	自由刑的中国命运	9
2.3	正当根据	10
2.3.1	报应刑论	10
2.3.2	功利刑论	10
2.3.3	综合刑论——报应与功利二元论	10
2.4	裁量、执行与消灭	11
2.4.1	刑罚裁量	11
2.4.2	刑罚执行	11
2.4.3	刑罚消灭	11
3	刑法导论	13
3.1	刑法的定义	13
3.1.1	刑法条文与刑法规范	13
3.2	刑法的特征	14
3.2.1	刑法是公法	14
3.2.2	刑法是强行法	14
3.2.3	刑法是成文法	15
3.2.4	刑法是实体法	15
3.3	刑法的悖论	15
3.3.1	刑法的伦理性与去伦理性	15
3.3.2	刑法的绝对性与相对性	15
3.3.3	刑法干预的无限性和有限性	15
3.3.4	刑法的工具性与目的性	16
3.3.5	刑法的最后手段理念和最先适用现实	16
3.4	刑法的机能	16
3.4.1	规制机能	16
3.4.2	法益保护机能	16

3.4.3	人权保障机能	17
3.5	刑法的原则	17
3.5.1	罪刑法定原则	17
3.5.2	法益保护原则	18
3.5.3	责任主义原则	18
3.6	刑法的解释	18
3.6.1	刑法解释的立场	18
3.6.2	刑法解释的边界	18
3.6.3	解释的方法	19
3.6.4	解释的规则	19
4	构成要件该当性	20
4.1	犯罪论体系：从四要件到三阶层	20
4.2	构成要件该当性的判断	21
4.3	客观构成要件要素	22
4.3.1	行为主体	22
4.3.2	实行行为	22
4.3.3	行为对象	25
4.3.4	行为情状	25
4.3.5	行为结果	25
4.3.6	因果关系	25
4.4	主观构成要件要素	28
4.4.1	故意	28
4.4.2	过失	28
4.4.3	目的、动机	29
4.5	但书规定与罪量要素	29
5	违法性	30
5.1	构成要件的违法推定机能与违法性的判断	30
5.2	违法性的内涵	30
5.2.1	形式违法性与实质违法性	30
5.2.2	主观违法性与客观违法性	30
5.2.3	结果不法论、行为不法论与二元不法论	31
5.3	阻却违法事由的原理与种类	31
5.4	法定的阻却违法事由	31
5.4.1	正当防卫	31
5.4.2	紧急避险	31

5.4.3	法令行为	31
5.5	超法规的阻却违法事由	32
5.5.1	被害人同意或承诺的行为	32
5.5.2	基于推定的承诺	32
5.5.3	自救行为	32
5.5.4	自损行为	32
6	责任	33
6.1	归责逻辑：从责任主义到责任阶层	33
6.1.1	刑事归责的路径演变	33
6.1.2	责任的多重内涵	33
6.2	责任理论：从心理责任到规范责任	33
6.2.1	心理责任论	33
6.2.2	规范责任论	34
6.3	责任要素：从二要素到四要素	34
6.3.1	责任能力	34
6.3.2	责任故意（过失）	35
6.3.3	违法性认识（可能性）	35
6.3.4	期待可能性	36
7	犯罪形态	38
7.1	共同犯罪	38
7.1.1	概念界定与问题本质	38
7.1.2	成立要件	38
7.1.3	共同犯罪的形式	39
7.1.4	共同犯罪人的种类及其责任	40
7.2	犯罪停止形态	41
7.2.1	犯罪既遂	42
7.2.2	犯罪预备	43
7.2.3	犯罪未遂	43
7.2.4	犯罪中止	46
7.3	罪数与竞合	49
7.3.1	典型的一罪与数罪	49
7.3.2	罪数不典型与竞合	49
8	侵犯国家法益的犯罪	50
8.1	国家法益概论	50

8.2	危害国家安全罪	51
8.2.1	“总体国家安全观”下国家安全法益的内涵	51
8.2.2	危害国家安全罪的类型	52
8.2.3	危害国家安全罪的特点	52
8.3	妨害国家职能之贪污贿赂罪	53
8.3.1	贪腐案件特点	53
8.3.2	贪污贿赂罪的种类	53
8.3.3	受贿罪的构成要件	56
8.3.4	贪污罪、受贿罪的量刑标准	58
8.4	妨害国家职能之渎职罪	59
8.4.1	类型	59
8.4.2	基本问题	59
9	侵犯社会法益的犯罪	62
9.1	危害公共安全罪	62
9.1.1	公共安全的界定	62
9.1.2	种类	62
9.2	破坏经济秩序罪	64
9.2.1	基本犯罪	64
9.2.2	重点犯罪	65
9.3	妨害社会管理秩序罪	72
9.3.1	《刑法修正案（十一）》的废改立	72
9.3.2	网络犯罪	76
9.3.3	黑恶犯罪	77
9.3.4	污染环境罪	77
9.3.5	走私、贩卖、运输、制造毒品罪	77
10	侵犯个人法益的犯罪	80
10.1	故意杀人罪	80
10.2	故意伤害罪	80
10.3	侵犯自由的犯罪	80
10.3.1	非法拘禁罪	80
10.3.2	绑架罪	80
10.3.3	拐卖妇女儿童罪	80
10.3.4	侵犯自由的其他犯罪	83
10.4	侵犯性自决的犯罪	83
10.4.1	强奸罪	83

10.4.2 奸淫幼女（法定强奸）	85
10.4.3	85

Part I

正文

第 1 章

犯罪导论

1.1 犯罪镜像

1.1.1 生活事实中的犯罪多面相

1.1.2 犯罪学视角的犯罪镜像

所有违反社会规范期待的反社会行为都是犯罪。

犯罪 = 法定犯罪 + 其他反社会行为

1.1.3 刑法学视角的犯罪镜像

概念

- 形式概念：刑法规定处以刑罚之违法行为。
- 实质概念：具有社会危害性应当处以刑罚的违法行为。
- 法定概念：社会危害性、刑事违法性和应受惩罚性。（刑法第 13 条）
- 理论概念：符合构成要件、违法且有责的行为。

1.1.4 犯罪的界定

- 域外通行模式：立法定性 + 司法定量
- 中国特色模式：立法定性 + 定量

1.2 犯罪类型

1.2.1 自然犯 v. 法定犯

——以行为之不法内涵为标准

- **自然犯**：违反人类怜悯、正直等道德情感的犯罪。
- **法定犯**：违反国家行政取缔、禁止或命令的犯罪。

- 自然犯的人伦性与法定犯的行政性
- 自然犯的恒常性与法定犯的易变性
- 自然犯与法定犯不法、罪责内涵的差异性
- 自然犯与法定犯区分的相对性
- 犯罪结构变迁与法定犯时代的新挑战！

1.2.2 重罪 v. 轻罪 v. 微罪（违警罪）

——以刑罚之轻重为标准

- **重罪**：刑法规定或者法院判决科处三年以上刑罚之罪
- **轻罪**：刑法规定或者法院判决科处三年以下有期徒刑之罪
- **微罪**：刑法规定或者法院判决科处一年以下自由刑之罪

1.2.3 故意犯 v. 过失犯

——以行为人对结果的主观犯意为标准

责任主义原则：行为非出于故意或过失不罚。

	故意犯	过失犯
分类	直接故意犯罪 + 间接故意犯罪	疏忽大意过失犯 + 过于自信过失犯
刑罚归责原则	普遍处罚	例外处罚
不法与罪责程度	较重	较轻

1.2.4 作为犯 v. 不作为犯

——以犯行之样态为标准

- **作为犯**：以积极的作为实现犯罪
- **不作为犯**：以消极的不作为实现犯罪

— 纯正不作为犯

* 嫌弃妻儿 = 遗弃罪？

- 不纯正不作为犯
 - * 老娘落水，儿子见死不救 = 故意杀人罪？
 - * 路人落水，行人见死不救 = 故意杀人罪？
 - * 见死不救 = 故意杀人？
- 不纯正不作为犯以保证人地位为前提

1.2.5 实害犯 v. 危险犯

——以行为是否实际造成损害为标准

- 实害犯：行为对行为客体造成实害结果才能既遂
 - 故意杀人罪、盗窃罪、抢劫罪等
- 危险犯：行为对行为客体惹起危险状态即为既遂。
 - 具体危险犯：危险作为构成要件要素
 - * 破坏交通工具罪
 - 抽象危险犯：危险作为构成要件行为属性
 - * 生产销售假药罪
- 危险犯与刑法干预前置化、风险社会的刑法风险

1.2.6 一般犯 v. 特别犯

——以行为主体有无身份要求为标准

- 一般犯：刑法对行为人的身份无特定要求
- 特别犯：刑法对行为人的身份有特别要求，仅主体适格者才能实施犯罪。
 - 纯正特别犯（定罪身份）
 - * 贪污罪、受贿罪、渎职犯罪
 - 不纯正特别犯（量刑身份）
 - * 诬告陷害罪（国家机关工作人员）

1.2.7 政治犯 v. 刑事犯

——以是否因政治立场不同而成立犯罪为标准

- 政治犯：出于政治目的特别是改变国家政治制度实施之罪。

- 刑事犯：非出于特定政治目的而实施之罪。
- 政治犯 = 思想犯？
- 政治犯与国事犯、反革命罪

1.3 犯罪原因

1.3.1 古典学派的自由意志论

- 代表人物：贝卡里亚、费尔巴哈、边沁
- 哲学基础：理性主义、自由意志与功利主义
- 犯罪原因：犯罪是具有自由意志的辟苦求乐的行为选择
- 犯罪对策：加大犯罪成本，使犯罪人犯罪之乐被刑罚之苦抵消。

1.3.2 犯罪人类学的解释

- 哲学方法：实证主义与进化论
- 基本立论：
 - 犯罪人通过体格和心理的异常表征区别于非犯罪人。
 - 犯罪人是退变到低级的原始人类型，犯罪是犯罪人的一种返祖现象。
 - 犯罪具有遗传性，是人类远祖犯罪基因隔代遗传的结果。犯罪人是天生犯罪人。
- 生理特征 + 精神特征
- 犯罪人类学 → 基因决定论；犯罪人类学者 → 基因的奴隶。
- 犯罪人类学的多面向：染色体异常（XYY、XXY?）、内分泌失调、体型、体质、智商、大脑前额叶皮层发育不完整、生化因素、纹身与犯罪
- 犯罪人类学的（反）科学性与政治不正确！

1.3.3 犯罪社会学的解释

- 涂尔干：社会失范理论
 - 失范是指社会对个人的欲望和行为的调节缺乏统一规范和足够制约力的社会状态。犯罪的实质是社会失范。失范对于社会的安定和发展具有双重性，危害社会安定与刺激社会变革。

- 菲利：三原因论与犯罪饱和法则
 - 每一个社会都有与其适应的犯罪，特定社会的犯罪是恒定的，除非社会环境发生激烈的变化和冲突，犯罪才可能暴增。
 - 犯罪原因分为人类学的、自然的和社会的原因三类，犯罪是人类学因素、自然因素和社会因素相互作用而成的一种社会现象。
- 李斯特：二原因论（个体 + 社会）
- 犯罪社会学的批判性和革命性！

1.3.4 犯罪心理学的解释

从精神、人格、情绪、行为学习等维度研究犯罪。

- 精神分析理论（弗洛伊德）
 - 本我、自我与超我、生（性）本能（性）与死（攻击）本能
- 情绪障碍理论（W·希利）
- 自我同一性危机理论（埃里克森：《童年与社会》）
- 犯罪学习、差异交往理论（萨瑟兰：《犯罪学原理》）。
 - 运用行为学习理论解释犯罪心理形成和犯罪行为发生机制。

1.3.5 犯罪经济学的解释

“加大犯罪成本才能有效控制犯罪”

1.3.6 马克思主义犯罪学的解释

- 哲学基础：辩证唯物主义与历史唯物主义
- 典型特征：注重阶级冲突的政治犯罪学
- 西方马克思主义犯罪学的新发展（理查德·昆尼与《新犯罪学》）
- 马克思主义犯罪学的结构性、反思性和批判性

1.3.7 综合原因论的解释

多维、分层、动态的犯罪原因要素与结构分析

- 行为人身体维度：遗传缺陷、先天或后天疾病、创伤、染色体、基因异常等。
- 行为人心理维度：智力低下、心理变态、精神癫狂、心智冲突等。
- 行为时社会环境维度：生活贫困、经济兴衰、失业、家庭、学校、居住环境、文化、风俗、信仰、宗教、仇恨、歧视、司法不公等。
- 行为时自然环境维度：地理、季节、气候、天气等（犯罪场）。

1.3.8 被害人学的新思维？

- 定义：基于被害与加害的互动关系研究如何避免被害与加害的经验科学。
- 要旨：犯罪是一种反社会因素的自我宣泄过程，积极的犯罪人和消极的被害人的关系是相辅相成的关系，正是被害人影响与塑造了犯罪人。——亨蒂格
- 延伸：从被害人学到被害人刑法教义学——被害人自我答责减免加害人罪责？

1.4 犯罪趋势

自然犯	→	法定犯
重罪	→	轻罪、微罪
自然人犯罪	→	法人犯罪
国内犯罪	→	国际、跨国犯罪
重罪	→	轻罪、微罪
物理空间犯罪	→	虚拟空间犯罪

1.5 犯罪对策

- 从惩罚、威慑到规训、改善
- 从重刑到轻刑、慎刑、无刑
- 从“刑期于无刑”到“徒法不足以自行”
- 从政府主导到政府、社会协同与技术防控

第 2 章

刑罚导论

2.1 概念与特征

概念 2.1. 刑罚：刑法规定并由法院依法对犯罪人适用的以限制或者剥夺其一定权利和利益为内容的刑事制裁措施。

刑罚的特征

- 刑罚法定
- 对象特定
- 痛苦属性
- 程序正义

2.1.1 刑罚与非刑罚正式制裁

2.1.2 刑罚与非正式制裁

2.1.3 犯罪前科制度与犯罪附随后果

2.2 结构与种类

2.2.1 刑罚结构

2.2.2 刑罚变迁——从野蛮到文明

- 以肉体摧残为中心 → 以心灵规训为中心
- 以重刑为中心 → 以轻刑为中心
- 以惩罚、报应为中心 → 以教化、矫正为中心

2.2.3 死刑的中国命运

死刑的存废、去留，并不取决于其自身无法辩明的正义性（或非正义性）以及无法证实或证伪的威慑性。

废止 or 保留？

死刑研究的四个维度

- 观念维度：改变公众认同，影响政治抉择
- 政策维度：从多杀到少杀再到不杀
- 立法维度：实体、程序与证据的多管齐下
- 司法维度：严格解释死刑适用条件，统一死刑适用标准

立法和司法双管齐下：通过实体法、程序法、证据法在法律规范的层面进一步限制和规制死刑的适用范围。

- 死刑的存废、去留，并不取决于其自身无法辩明的正义性（或非正义性）以及无法证实或证伪的威慑性。
- 死刑制度在根本上是一个受集体意识的公众认同以及政治领袖的政治意志左右的政策选择问题。

2.2.4 自由刑的中国命运

概念 2.2. 自由刑：以剥夺人的基本权利之一的自由为主要内容的刑罚，受刑者在一定的设施内被拘禁。在中国大陆，管制、拘役、有期徒刑和无期徒刑都属于自由刑的范围。

自由刑的功能

- 隔离或剥夺功能：拘禁犯罪人使其与社会隔离，剥夺其继续实施犯罪能力的功能。
- 惩罚功能：剥夺犯罪人的自由作为对其恶行的报应性惩罚以恢复正义的功能。
- 威慑功能：借剥夺犯罪人的自由吓阻犯罪人本人以及社会一般人的威慑功能。
- 矫正功能：在拘禁状态中对犯罪人进行教化训练的教育改善功能。

自由刑的悖论

- 惩罚报应与教育矫正的悖论
- 行刑过程与行刑目标的悖论

短期自由刑

- 困境与出路
 - 短期自由刑虽短得不足以使受刑人改好，却长的足以使受刑人变坏？
 - 短期自由刑 = “剧烈短促的打击”(sharp and short shock)？
- 救济与替代
 - 限制短期自由刑。短期自由刑作为刑事政策上的“最后手段条款”？
 - 改善短期自由刑。
 - 替代短期自由刑。

终身监禁

- 可以假释的终身监禁
- 不得假释的终身监禁
- 终身监禁的死缓（中国特色与制度创新）：【第 383 条】犯贪污、受贿罪，被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

自由刑的未来：行刑社会化与社区矫正

2.3 正当根据

2.3.1 报应刑论

2.3.2 功利刑论

2.3.3 综合刑论——报应与功利二元论

- 报应和功利的形式对立：报应着眼于已然之罪，具有回顾性，强调刑从罪生，罪有应得，罪刑相当；功利着眼于未然之罪，具有前瞻性，强调刑须制罪（必要条件）

和刑足制罪（充分条件）。

- 报应和功利的内在统一：报应和功利之间的对立实际只有相对和形式的意义，形式对立的表层之下蕴藏着内在统一，存在相互妥协和调和的余地。
- 报应和功利的并合：报应和功利同时说明国家行使刑罚权的正当性、设定刑罚的合理限度：报应设定刑罚上限，在报应刑限度追求功利目标。

2.4 裁量、执行与消灭

2.4.1 刑罚裁量

- 刑罚裁量原则：短期自由刑作为刑事政策上的“最后手段条款”？
- 刑罚裁量情节：法定与酌定；从宽与从严
- 刑罚裁量制度：自首 + 立功 + 坦白 + 数罪并罚 + 缓刑
- 认罪认罚从宽制度
- 刑事合规与合规整改不起诉？

2.4.2 刑罚执行

- 刑罚执行对象：人民法院已经发生法律效力的判决、裁定。
- 刑罚执行主体：人民法院、监狱、公安机关。
- **减刑**：对被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在刑罚执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现或者立功表现，将其原判刑罚予以适当减轻的刑罚执行制度。
- **假释**：对于判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行一定期限的刑罚后，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，确实不致再危害社会的，将其附条件地予以提前释放的刑罚执行制度。

2.4.3 刑罚消灭

- 刑罚消灭事由
 - 超过追诉时效
 - 经特赦免除刑罚
 - 告诉才处理的犯罪没有告诉或撤回告诉

- 犯罪嫌疑人、被告人死亡
 - 其他事由
- 刑罚消灭与诉讼时效、行刑时效

第 3 章

刑法导论

3.1 刑法的定义

何为刑法？

刑法是规定犯罪及其法律后果的法律规范。

关键词：犯罪、法律后果、刑事责任、刑罚、保安处分（指国家为了维护社会秩序、预防犯罪，对具有社会危险性但不一定构成犯罪或虽构成犯罪但不宜仅以刑罚处理的人，所采取的具有强制性、预防性、矫治性或保护性的法律措施。）

3.1.1 刑法条文与刑法规范

刑法条文

刑法条文 = 刑法总则 + 刑法分则

- 刑法总则的构造：刑法的制定根据、原则、犯罪成立的一般条件与刑罚制度
- 刑法分则的构造：个罪成立要件 + 法律后果
- 刑法总则是刑法分则的抽象，指导刑法分则的解释与适用
- 刑法条文是刑法规范的载体，刑法规范是刑法条文的内容

刑法规范

刑法规范 = 行为规范 + 裁判规范

- 行为规范 = 评价规范 + 决定规范
 - 评价规范：根据刑法的评价标准判断行为是否违法并应受刑法非难。

- 决定规范：命令国民作出服从刑法的意思决定与行为选择。
- 适法期待——提出符合法秩序的义务要求，否则将招致不利法律后果；
- 自由保障——提供法自由与安全的保障，使国民具有行为后果的预测可能性和行为选择的自律可能性。
- 裁判规范：当且仅当存在该当法定构成要件的行为，才能通过裁判实际发动刑罚。
 - 命令法官对符合法定构成要件的行为依法定罪处罚；
 - 禁止法官对不符合法定构成要件的行为非法发动刑罚。

3.2 刑法的特征

3.2.1 刑法是公法

约束具有公共冲突性质的行为。

- 公法主旨：通过法律规制公权力、保障私权利
- 公权力：法无授权不可为
- 私权利：法无禁止即可为

3.2.2 刑法是强行法

刑法以国家刑罚权的行使为基础，具有绝对适用的效力，行为人或被害人无左右或变更刑法适用之权利。

例外？

1. 告诉乃论罪（亲告罪）
2. 被害人同意阻却犯罪
3. 起诉便宜主义
4. 辩诉交易与认罪认罚从宽
5. 恢复性司法与刑事和解
6. 监狱私营化？

3.2.3 刑法是成文法

成文法具有契约性质，是国家与公民间的契约。

“刑法契约化”

↓

“良法”“善法”

3.2.4 刑法是实体法

- 刑法规定行为构成犯罪的要件及其法律效果等实体内容。
- 刑事诉讼法规定如何追诉犯罪等程序内容。

3.3 刑法的悖论

3.3.1 刑法的伦理性与去伦理性

- 伦理规范作为刑法规范之基础，刑法维持最低限度的伦理规范
- 刑法的法律效果具有伦理非难性
- 刑法与道德的区分及其相对性
- 刑法规制具有伦理非难可能性的行为
- 法定犯的伦理非难性？
- 刑事制裁的伦理许可性！

3.3.2 刑法的绝对性与相对性

刑法的绝对性 = 泛刑法主义 + 刑法万能主义 + 重刑主义 **错误！**

刑法的相对性 = 规范内容不完整性 + 规范功能相对性

- 规范内容不完整性：片断性、滞后性、刑法漏洞的不可避免性。
- 规范功能相对性：局限性、副作用。

3.3.3 刑法干预的无限性和有限性

1. 刑法干预范围

- 无被害人犯罪与刑法的去道德化

2. 行为刑法原理

- 思想犯、信仰犯与人的思想、信仰的不可罚性

3. 社会危害原则

- 没有法益侵害就没有犯罪
- 刑法家长主义与个人自我决定权

3.3.4 刑法的工具性与目的性

刑法既是手段，也是目的。

刑法价值：维护秩序、保障自由、实现正义。

3.3.5 刑法的最后手段理念和最先适用现实

- 刑法是第二次法，对法益进行辅助性保护。
- 最后手段性作为刑法立法原则和刑事司法原则。
- 风险社会的风险控制、刑法的预防性转向与刑法最先适用的趋势。

3.4 刑法的机能

3.4.1 规制机能

- 行为规范——刑法规范指向国民，具有评价功能和意思决定功能，评价和规范国民行为。
- 裁判规范——刑法规范指向司法者，命令和规制司法者裁判行为是否构成犯罪、对犯罪如何追究刑事责任和适用刑罚。

3.4.2 法益保护机能

刑法是法益保护法（主流观点）

法益保护与规范确证（结果不法与行为不法）之争

结果无价值 or 行为无价值

- 结果无价值：违法性的本质在于“法益侵害或危险的结果”——即行为是否造成或可能造成法律所保护的利益（生命、财产、自由、秩序等）的损害。
 - 刑法的目的是保护法益；
 - 行为之所以违法，是因为它客观上侵害或威胁了法益；
 - 行为人的主观意图、动机、行为样态（如是否“恶劣”）不影响违法性判断，

只影响责任（有责性）。

- 行为无价值：违法性的本质在于“行为本身的反规范性、反伦理性”——即行为是否违反了社会共同生活所要求的行为规范，是否具有“伦理上或规范上值得谴责的性质”。
 - 刑法不仅是保护法益，更是维护社会行为规范与伦理秩序；
 - 即使没有实际结果，只要行为本身“违反规范”（如故意杀人未遂、危险驾驶），就具有违法性；
 - 行为人的主观意图、行为方式、动机等，直接影响违法性判断。

3.4.3 人权保障机能

刑法不单纯以保护国家利益为出发点、以国民为规制对象，也以保护国民利益为出发点、以国家为规制对象。

刑法是限制刑罚权、保护人权的大宪章。

刑法不仅要面对犯罪人以保护国家，还要面对国家保护犯罪人；不单面对犯罪人，还要面对检察官保护公民，成为公民反对司法专横和错误的大宪章。

法益保护和人权保障的对立统一、善良国民的大宪章与犯罪人的大宪章的一体两面！

3.5 刑法的原则

3.5.1 罪刑法定原则

法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。

现代法治 = 规则之治 + 良法之治 + 良法善治

罪刑法定的内涵

- 形式侧面
 - 法律（专属）主义
 - 禁止事后法及其例外（从旧兼从轻）
 - 禁止类推适用及其例外
 - 禁止绝对不确定刑
- 实质侧面
 - 刑法的明确性

- 刑法的适正性：适当的犯罪化、适当的刑罚处罚

罪刑法定的机能

- 法外入罪禁止机能——依法入罪！
 - “法无明文规定不为罪”= 法无明文规定必定无罪！
 - 罪刑法定容忍刑法漏洞、轻纵坏人?!
- 法内出罪容许机能——合理出罪！
 - “法无明文规定不为罪”= 法有明文规定必定有罪？**未必！**

法益作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据。

3.5.2 法益保护原则

3.5.3 责任主义原则

3.6 刑法的解释

3.6.1 刑法解释的立场

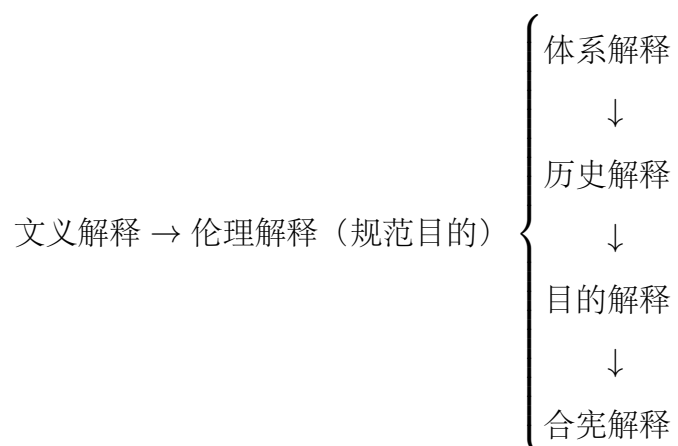
刑法解释的目标设定：

- 主观解释论抑或客观解释论？
 - 探询立法者通过法律文本表达的立法原意。
 - 发现法律文本现在应有的客观意思。
- 折中解释论？
- 解释不能论？

3.6.2 刑法解释的边界

- 形式解释论：字面文义优先的解释论？（限制刑罚权）
- 实质解释论：处罚必要性优先的解释论？（容易先入为主，“欲加之罪，何患无辞”）

3.6.3 解释的方法



3.6.4 解释的规则

- 同一律规则：体系解释与法秩序统一性的绝对要求？
- 排他律规则：立法的“明示列举”与解释的“明示其一排除其余”
- 只含同类规则：“兜底条款”与“概括性规定”如何解释？
- 严格解释规则：严格解释的标准与程度如何判断？
- 正确解释规则：刑法文义存疑时进行有利于被告的解释？
- 生活逻辑规则：吸纳生活经验与常识常理，贯通天理、国法与人情！

第 4 章

构成要件该当性

4.1 犯罪论体系：从四要件到三阶层

概念：以刑法规定为基础，根据一定原理和方法，将犯罪成立要素组织化的知识体系。

功能：定罪思维模型、规训司法定罪过程。

传统——四要件犯罪构成理论

- 行为符合犯罪构成是定罪的唯一根据、充分必要条件。
- 犯罪构成是刑法规定的决定行为社会危害性及其程度而为行为构成犯罪所必不可少的主客观要件的总和。

犯罪客体 + 客观方面 + 犯罪主体 + 主观方面

超越——三阶层犯罪论体系

- 犯罪是该当（符合）构成要件的违法且有责的行为。
- 犯罪构成要件：

构成要件该当性 + 违法性 + 有责性

1. 构成要件该当性

- 构成要件是罪刑法定原则的基本载体。
- 构成要件该当性是犯罪成立必要条件，但非充要条件。
- 构成要件是法定的行为类型，积极地证立行为的不法和行为人的责任。
- 构成要件该当性的审查：根据刑法分则规定，判断行为是否齐备某种犯罪的构成要件要素。

2. 违法性

- 违法性要件是法益保护主义的要求。
- 违法性阶层的审查：立足于整体法秩序，判断该当构成要件的行为是否确实具有违法性，注重发现与判断是否存在违法阻却事由。
- 违法阻却事由：法定违法阻却事由与超法规违法阻却事由。

3. 有责性

- 有责性要件是责任主义原则的要求。
- 有责性的审查：对行为人进行具体判断、个别考察与规范评价，确认行为人是否应当对该当构成要件的违法行为负责，审查是否存在阻却责任的事由。
- 责任阻却事由：法定的阻却责任事由与超法规的阻却责任事由。

三阶层体系之比较优势：平衡控辩职能，控制法官的思维过程，疏通入罪与出罪渠道，过滤、限缩定罪范围。**出罪功能强于四要件犯罪构成理论。**

三阶层犯罪论体系的中国化与本土化

- 三阶层犯罪论体系作法律思维方法与定罪思维模型，具有普适性；
- 三阶层犯罪论体系的基本构造契合中国刑法基本规定；
- 三阶层犯罪论体系需要结合中国刑法规定进行本土化发展。

4.2 构成要件该当性的判断

即被告人行为是否符合构成要件？

——构成要件要素是否齐备？这些要素是否按照法律规定或学理认可的组合方式展开？

构成要件要素

- 构成要件要素是行为符合某种犯罪的构成要件必须具备的要素。
- 构成要件要素 = 客观构成要件要素 + 主观构成要件要素。

1. 客观构成要件六要素

行为主体 + 实行行为 + 行为对象 + 行为情状 + 行为结果 + 因果关系

2. 主观构成要件要素：支配行为人实施构成要件行为并惹起结果的心理要素。

故意 过失 目的、倾向

4.3 客观构成要件要素

4.3.1 行为主体

行为主体的种类：自然人与法人（单位）

1. 自然人主体：一般主体与特殊主体（一般犯与身份犯）
2. 法人（单位）主体
 - 现代社会治理需求与法人刑事责任。
 - 刑事责任的个人属性与法人刑事责任的团体属性存在紧张性。
 - 法人犯罪的本质是自然人犯罪，法人刑事责任是拟制刑事责任。

单位犯罪（中国特色）

- 公司、企业、事业单位、机关、团体实施的法律规定为单位犯罪的危害社会的行为。（第 30 条）
- 以双罚制为原则、以单罚制为例外
- 成立条件：
 - (1) 刑法特别明文规定；
 - (2) 主体限于公司、企业、事业单位、机关和团体；
 - (3) 出于单位的犯罪意志；
 - (4) 为单位谋取非法利益。

4.3.2 实行行为

实行行为：对法益创设侵害危险的身体举止。

- 无行为就无犯罪亦无刑罚！
- 思想、言论、身份、状态的可罚性？
- 言论入罪的法理根据

- 言论的入罪标准——明显、即刻而严重的危险？

行为的要素

举止性（身体动静）+ 有意性

1. 不具有有意性的举止不是行为

- 反射动作
- 催眠动作
- 本能动作（抽搐、梦游）
- 动物攻击
- 自然事件

2. 具有有意性的行为

- 自动行为
- 冲动行为
- 精神胁迫行为
- 忘却行为
- 原因自由行为（指行为人在具有完全刑事责任能力时（原因阶段），故意或过失地使自己陷入无责任能力或限制责任能力的状态（如醉酒、吸毒、服用药物等），并在此状态下实施了符合构成要件的违法行为（结果阶段））

行为形式

作为：违反禁止规范的积极的身體動作。

不作为：不履行命令规范要求的作为义务的身体举止。

- 作为的形式：
 - 利用自身动作
 - 利用机械力
 - 利用自然力
 - 利用动物
 - 利用他人（间接正犯）

- 不作为犯罪 = 纯正不作为犯罪 + 不纯正不作为犯罪
 - 纯正不作为犯罪：刑法明文规定只能以不作为形式构成的犯罪；（如遗弃罪，拒不执行判决、裁定罪）
 - 不纯正不作为犯罪：以不作为方式实施通常由作为方式实施的犯罪。（如母亲不给婴儿喂奶至其饿死）

不纯正不作为犯的法理依据：

- 基本根据：法益保护的客观需要。
- 必要限制：人权保障对不作为犯范围的规制。
- 法律根据：借用作为犯的法条？刑法特别授权？
- 问题的实质：刑法分则没有特别规定作为义务主体与作为义务内容时，如何确定不纯正不作为犯的处罚范围？

例：故意杀人法条

规范目的：保护生命法益。

规范形式：禁止性规范与命令性规范。

不作为犯的成立条件

1. 应作为——行为人负有防止结果发生的作为义务（保证人地位）。
 - 传统的保证人类型
 - 保证人地位实质化
2. 能作为——“刑法不强人所难”
3. 不作为——不为期待应为之行为

形式的作为义务	实质的保证人地位
法律规定	对于特定法益的保护义务
契约约定	对于特定危险源的监督义务
先行行为	

不作为与作为等价性的判断

- 作为与不作为存在结构具有差异：作为能够引起因果关系的发生，并能支配、操纵结果的发生方向。不作为只是利用因果关系发生结果。
- 不纯正不作为犯的等价性：为了让不纯正不作为犯与作为犯等置在同一构成要件上，就必须采取填补存在结构上的空隙的办法，使得两者在价值方面等同。
- 等价性的判断是对不纯正不作为犯贯彻罪刑法定的关键。

4.3.3 行为对象

行为对象：实行行为侵犯或者指向的人或物。

- 行为对象是保护法益的载体，但行为对象不是保护法益。
 - 甲男强奸乙女，乙女为行为对象，乙女的性自主决定权为保护法益。
- 行为对象是否存在？
- 行为对象是否适格？

4.3.4 行为情状

行为情状：实行行为成立特定犯罪所必需的特定情境（时间、空间等）。

4.3.5 行为结果

行为结果：实行行为惹起法益实际损害结果或者侵害危险状态。

- 行为犯是行为与法益侵害结果同在的结果犯。
- 实害犯之实害结果
- 危险犯之危险结果。
 - 危险结果包括具体危险结果（如放火罪）与抽象危险结果（如醉酒驾驶机动车罪）。

4.3.6 因果关系

- 实行行为与行为结果之间的因果联系与责任归属。
- 事实因果关系以自然因果法则为判断基准。

- 责任归属以法规范的标准判断结果的归责。
- 作为犯的因果关系（因果律——规范评价）与不作为的因果关系（规范评价——因果律）。

条件说

- 条件说的经典公式：只要存在着没有 A 即没有 B 的条件关系，A 就是 B 的原因。
- 只要行为与结果间存有“条件关系”，即承认有刑法上之因果关系；
- 肯定所有先行事实（行为），对结果之发生均具原因力。
- 所有条件对结果之发生都具同等价值，故称“等价说”。

原因说

- 从导致结果发生的条件中，以某种规则为标准挑选其中应当作为原因的条件，只有这种原因与结果之间才存在刑法因果关系。
- 原因说的目的——避免根据条件说认定的因果关系范围过大之缺点。
- 分类：
 - (1) 必要原因说：以多数前行为中必然引起结果发生的，为结果发生的原因，其余为条件。
 - (2) 优势原因或决定原因说：以多数前行为中，对于结果的发生具有优势力量或有决定性的力量者，为结果发生的原因，其余为条件。
 - (3) 最终原因说：以多数前行为中，最后的行为为结果的原因，此前的行为为条件。
 - (4) 异常原因说：在生活上违反常规所实施的行为就是原因。否则即非原因。

相当因果关系说

- 在行为与结果存在条件关系时，参照社会生活上经验，通常认为该行为可能导致该结果的，具有刑法因果关系。
- 成立要件：
 - 存在条件关系——如无该行为，该结果就不会发生。

- 存在相当性——对存在条件关系之行为和结果，参照社会生活经验，判断先行事实与后发结果间是否存有相当性。

客观归责说：从事实归因到规范归责

客观归责的要义：区分事实层面的归因和规范层面的归责

- 归因是归责的前提，肯定条件因果后再筛选刑法上值得归责的原因。
- 若行为人藉由实行行为
 - (1) 对行为对象制造了法所不容许的风险
 - (2) 不法风险在具体结果之中实现了
 - (3) 结果存在于构成要件效力范围之内
- 则由该行为所引起的结果，才能被认为是行为人的成果而归责于行为人。

客观归责的检验规则：

1. 检验行为人的行为是否制造了不被容许的风险

- 没有制造风险 → 降低风险 → 风险被容许 → 制造了法不容许的风险
- **行为人的行为必须对行为对象制造了法所不容许的危险。**
- 没有制造法所不容许的风险——行为与结果虽有因果关系，但该行为仍在法所容许的范围内，该结果不能归责于行为人。
- 降低风险者并未制造法所不容许的风险。
- **制造可容许的风险的行为：**中立的帮助，交通信赖，立法者所容许的风险作业。

2. 检验行为人是否实现了不被容许的风险

- 行为与结果虽有因果关系，且行为人制造法所不容许的风险，但须实现该不法风险，才能归责。如果结果虽然发生，但并非基于该风险所导致，则因无风险实现而不可归责。
- 结果与行为的常态关联（溺死撞死案）、结果的可避免性（山羊毛案）、注意规范保护目的（心肌梗死案）

3. 检验构成要件的效力范围

- 检验结果是否属于他人负责或自我负责（答责）的领域。

疫学因果关系说

因子（行为）与疾病（结果）之间的关系，在医学、药理学上即使得不到科学证明，但根据大量的统计、观察，能说明该因子对产生疾病（结果）具有高度的盖然性时，肯定其因果关系。

- A. 该因子在发病的一定期间之前起作用；
- B. 该因子的作用程度越显著，患病率就越高；
- C. 该因子的分布消长与疫学观察记载的流行特征并不矛盾；
- D. 该因子作为原因起作用，与生物学起作用并不矛盾。

4.4 主观构成要件要素

4.4.1 故意

《刑法》第 14 条：明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。

- 故意内容：认知 + 意欲；
- 故意种类：直接故意 + 间接故意

4.4.2 过失

《刑法》第 15 条：应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。

- 过失种类：疏忽大意的过失 + 过于自信的过失
- 过失犯的处罚：以处罚故意犯为原则、以处罚过失犯为例外。

罪过形式	认识因素	意志因素
直接故意	认识到必然或可能发生	积极追求
间接故意	认识到可能发生	放任，发生不违背意志
过于自信过失	认识到可能发生，但本应避免	不想发生，发生违背意志
疏忽大意过失	没有预见，但应当预见	不想发生

间接故意与过于自信过失的区别

- 前者接受并放任构成要件结果实现的风险，后者信赖构成要件结果不会发生；
- 前者具有与法规范敌对的意思，后者仍存在对法规范的忠诚。

4.4.3 目的、动机

1. 目的

- 行为人对实行行为侵害法益的目标设定。
- 法定目的犯与非法定目的犯。

2. 动机

- 驱使行为人实施实行行为的内在动力。
- 猥亵罪的性动机作为构成要件要素？

4.5 但书规定与罪量要素

《刑法》第13条：一切危害国家主权……以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。

- 但书的出罪指引功能——行为性质虽与构成要件行为相同，但是，如果“情节显著轻微危害不大”的，不认为是犯罪。
- 数额型罪量、结果型罪量、情节型罪量作为构成要件要素。

第 5 章

违法性

5.1 构成要件的违法推定机能与违法性的判断

- 构成要件具有违法推定机能，但推定不等于认定。
- 行为该当构成要件只是判断行为不法的必要条件（行为不该当构成要件即无不法可言——罪刑法定的当然要求），而非充要条件（该当构成要件未必不法）。
- 行为该当构成要件并且排除阻却违法事由时，才能认定其具有违法性。

法秩序统一性：该当构成要件的行为是否与整体法秩序相对立、冲突，是否为整体法秩序所容忍。

刑法违法性判断的相对性：民法或行政法允许的行为，不具有刑事违法性；民法或行政法禁止的行为，未必具有刑事违法性；民法或行政法不予保护的利益，不能认定侵害利益的行为具有刑事违法性。

5.2 违法性的内涵

5.2.1 形式违法性与实质违法性

形式违法性：违法性是外在客观的判断，构成要件该当行为只要形式上没有法定阻却违法事由，即认定其违法性。——古典学派

实质违法性：行为的违法性不仅取决于行为触犯刑罚法规，而且取决于社会危害。——新古典学派

实质的违法性与超法规违法阻却事由的承认是通说。

5.2.2 主观违法性与客观违法性

主观违法性：

- 法是命令规范，法规范的对象是能够理解命令、具有责任能力的人。

- 违法性是具有责任能力的人的行为的违法性。无责任能力的人的行为不具有违法性。
- 没有“没有责任的不法”。

客观违法性：

- 判断行为是否违法，无需考虑行为人的主观心理状态，只需单纯从行为的外在形态作出判断。
- 区分客观违法与主观责任，“没有责任的不法”也是不法！
- 无责任能力人的行为具有违法性。对无责任能力的人的不法行为可以正当防卫。

5.2.3 结果不法论、行为不法论与二元不法论

5.3 阻却违法事由的原理与种类

5.4 法定的阻却违法事由

5.4.1 正当防卫

5.4.2 紧急避险

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的损害另一法益的行为。

为保全自己而牺牲他人，能否构成紧急避险？

- 黑格尔的否定说 VS 康德的肯定说
- 无选择可能性说（自由意志说）
- 程序正义说
- 减小损害规则（功利主义）
- 法外空间说（放任说）
- 合理犯罪技术说（赵汀阳）

功利主义抑或道德主义？

5.4.3 法令行为

基于法律、法令之规定，行使权利或者履行职责的行为。

客观上可能造成某种法益损害结果，但由于其依法律、法令行使权利或履行职责的行为，故为排除犯罪的事由。

5.5 超法规的阻却违法事由

5.5.1 被害人同意或承诺的行为

5.5.2 基于推定的承诺

5.5.3 自救行为

在法益受到不法侵害而又无法诉诸公权力予以及时救济的情况下，出于自卫的本能，而进行

5.5.4 自损行为

行为人故意损害自己的法益的行为，如自杀、自残、故意烧毁或者毁坏自己的财产等。

第 6 章

责任

6.1 归责逻辑：从责任主义到责任阶层

6.1.1 刑事归责的路径演变

- 从客观归罪到主观归罪？
- 从团体责任到个人责任？
- 从行为责任到行为人责任？
- 从绝对责任（严格责任）到罪过责任？

6.1.2 责任的多重内涵

责任主义与人性尊严：人是目的，不是工具；人具有主体性；人具有规范的可交谈性。

- 构成刑罚基础的责任：刑罚以责任为基础。没有责任，就没有犯罪，亦没有刑罚。
- 与行为同在原则的责任：责任存在的时点是行为人实施构成要件行为之时。
- 构成要件、违法性之后作为犯罪成立要件的责任。
- 与不法行为对应的责任（行为人仅就其不法行为承担责任）
- 限定刑罚处罚程度的责任（责任作为刑罚裁量的基准）

6.2 责任理论：从心理责任到规范责任

6.2.1 心理责任论

- 责任是行为人的心理与行为的关系。
- 责任的种类：故意与过失。
- 责任能力为责任的条件。具有责任能力的人具有故意、过失时，即肯定责任。

6.2.2 规范责任论

- 在法律规范的关系上把握责任。
- 人能够理解规范的命令与禁止，具有他行为能力，能够期待其根据规范的命令或禁止实施合法行为时，才能进行责任非难。
- 核心命题：期待可能性（癖马案）

6.3 责任要素：从二要素到四要素

6.3.1 责任能力

理解行为事实并根据这种理解进行行为的能力。由理解能力和控制能力构成。

- 分为完全责任能力、限制责任能力、无责任能力。
- 立法推定实施不法行为的成年人具有责任能力。
- 精神疾病、未成年、原因自由行为特别是醉酒犯罪的责任能力。

1. 精神疾病与责任能力

- 刑法第 18 条与精神病、间隙性精神病、精神耗弱
- 司法判断：兼顾精神医学、心理学与法学标准。
- 完全错误的做法：直接依赖精神病鉴定结论，确定有无责任能力。
- 有待商榷的做法：直接拒绝进行精神病鉴定！
- 其他严重的精神错乱？
- 堪与病理性精神错乱相比较的非因身体性疾病而在心理上严重偏离正常人的精神错乱
- 心理变态、神经官能症、性欲异常、异常癖好排除责任能力？
- 学说与判例的倾向。

2. 未成年与责任能力

- 刑法第 17 条的四分法与刑事责任年龄
- 不满 14 周岁的未成年人不具有责任能力 = 不可反驳的法律推定？
- 英国的恶意补足年龄 = 可以反驳的法律推定？
- 刑法修正案十一下调刑事责任年龄的规定及其争议。

3. 原因自由行为与醉酒后犯罪

- 原因自由行为：行为人虽然在实施构成要件行为导致结果发生（结果行为）时处于无责任能力状态，但在较早的还有责任能力的时点上故意或过失地为该结果设置原因（原因行为）。
- 故意的原因自由行为：故意导致责任缺陷状态，原因行为指向特定故意犯行，结果行为实现了特定犯行。——借酒壮胆强奸！
- 过失的原因自由行为：故意或过失地导致责任缺陷状态，因而在责任缺陷状态下实现犯行。——酒后驾车肇事！
- 刑法第 18 条第 4 款：醉酒的人犯罪的，应当负刑事责任。

4. 没有责任能力与保安处分

- 精神病人的强制医疗
- 未成年人的专门矫治教育
- 与责任能力无关的其他保安处分措施：强制戒毒、禁止执业、安置教育

6.3.2 责任故意（过失）

- **责任故意**是行为人通过不法行为所体现出来的敌视法规范或者对法规范漠不关心的态度。
- 具备构成要件故意时，原则上具有罪责故意，但在假想防卫时，不能肯定责任故意。
- **责任过失**是行为人通过过失行为表现的对注意义务所体现的注意规范的疏忽或轻视态度。

6.3.3 违法性认识（可能性）

行为人认识到自己的行为不被法所允许（可能性）。

1. 行为人认识到自己的行为不被法所允许（可能性）。
 - 对刑法禁令（自然犯）的无知以及对行为所触犯的前置法（法定犯）的无知，不得成为免责抗辩理由。
 - 不得因对法律的无知而免责。
 - 违法性认识错误不阻却责任。
2. 新近学界主张（个别实务见解）

- 违法性认识可能性是独立的责任要素，违法性认识错误即禁止错误可能阻却或减轻责任。
- 可以避免的禁止错误可以减轻责任。
- 不可避免的禁止错误得阻却责任。

6.3.4 期待可能性

期待可能性（期待可能性的不存在）：在行为人实施犯罪的场合下，在行为时的具体状况下不可能期待他能够实施不是该犯罪行为的其他合法行为。

- 期待可能性是判断行为人行为时的心理状态的一种规范标准，并非违法犯意的心理事实（故意）。
- 缺乏期待可能性可以构成阻却责任或者减免责任的事由。
- 缺乏期待可能性：一般的超法规的责任阻却事由，还是法定的阻却责任事由？
- 本人立场：第四责任要素说

警察圈套与期待可能性？

- 机会提供型警察圈套—不得阻却责任
- 犯意诱发型警察圈套—可能阻却责任

义务冲突与期待可能性？

- “救老婆”还是“救老娘”的悖论与义务冲突

安乐死与期待可能性？

免责的防卫过当与期待可能性？

免责的紧急避险与期待可能性？

受虐妇女综合征与期待可能性

- 受虐妇女综合症：生活在暴力虐待关系中的妇女所表现出的某些共同的心理和行为反应。
- 一是创伤事件的侵入性回忆；二是过度觉醒和高度焦虑；三是通常表现为抑郁、分裂、最小化、压抑和否认的回避行为和情绪麻木；四是情绪和认知上的消极改变；五是殴打者的权力和控制措施导致人际关系破裂；六是身体形象扭曲和/或身体或物理上的抱怨；七是性问题。
- 受虐妇女综合症的主要理论根据，是习得性无助理论与暴力循环理论。

个罪中的期待可能性

- 亲亲相隐：（近亲属作伪证、毁灭、伪造犯罪、窝藏、包庇）
- 逃避包办、买卖婚姻或被拐卖后重婚

期待可能性的泛化与滥用？

第 7 章

犯罪形态

7.1 共同犯罪

7.1.1 概念界定与问题本质

- 概念界定：二人以上共同故意犯罪
- 核心问题——集体行为中的个人责任！
- 一个人要实施犯罪，是否必须自己亲自下手？
- 没有亲自出场、下手的人，是否、为何具有可罚性？何时具有可罚性？具有何种程度的可罚性？

7.1.2 成立要件

1. 主体要件——二人以上
 - 自然人/单位
 - 无责任能力人的参与
2. 客观要件——共同行为
 - 实行行为、组织行为、教唆行为和帮助行为
3. 主观要件——共同故意
 - 各参与者通过意思联络，认识到共同行为会发生危害社会的结果，并决意参与，共同追求或放任这种结果发生的心理状态。

问题与分歧

- 片面共犯能否以共同犯罪论处？
- 共同过失犯罪的能否以共同犯罪论？

- 基于不同罪过参与犯罪是否成立共同犯罪?
- 同时犯是否成立共同犯罪?
- 同时实施犯罪而犯意内容不同，是否成立共同犯罪?

7.1.3 共同犯罪的形式

1. 以是否能够任意形成作为标准区分

- 任意共同犯罪：法条规定可以由一个人单独实施也可以由二人以上共同实施构成的共同犯罪。
- 必要共同犯罪：法条规定只能二人以上共同实施才能构成的共同犯罪。
 - 必要共同犯组织 = 聚合性共同犯罪和集团性共同犯罪两种形式。
 - * 聚众扰乱社会秩序罪、聚众冲击国家机关罪。
 - * 组织、领导、参加黑社会性质组织罪等。

2. 以共同犯罪故意形成时间为标准区分

- 事前通谋共同犯罪：共同犯罪故意经事先预谋、策划，形成于着手实行犯罪前的共同犯罪。
- 事前无通谋共同犯罪：共同犯罪故意形成于着手实行犯罪之时或实行犯罪过程中的共同犯罪。

3. 以行为时有无明确分工为标准区分

- 简单共同犯罪：二人以上共同直接着手实行刑法分则构成要件行为的共同犯罪。——共同正犯
- 归责原则：部分实行全部责任原则
- 复杂共同犯罪：各犯罪参与者之间存在教唆、实行或帮助行为分工的共同犯罪。
- 复杂共同犯罪 = 实行犯（正犯）+ 教唆犯 + 帮助犯（狭义共犯）。
- （狭义）共犯与正犯的关系问题，是理解复杂共同犯罪的关键。
- 正犯的类型：
 - 直接正犯与间接正犯
 - 单独正犯与共同正犯

- **正犯与共犯的关系**

- 正犯与共犯的关系，存在共犯的从属性和独立性之争。
 - * 狭义共犯（教唆犯、帮助犯）的犯罪性是来自正犯的行为还是来自狭义共犯自身的行为。
- 共犯从属性说：共犯的犯罪性来自正犯的行为；
 - * 最极端从属性说；极端从属性说；限制从属性说；最小从属性说
- 共犯独立性说：共犯的犯罪性源于自身的教唆、帮助行为。

4. 以有无稳定组织形式为标准区分

- 一般共同犯罪：没有稳定的组织形式、为实施特定犯罪而临时纠集在一起实施的共同犯罪。
- 特殊共同犯罪（集团犯罪）：三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织实施的共同犯罪。

区分

- 犯罪集团与犯罪团伙、聚众性犯罪以及黑社会性质组织的区分：
- 犯罪团伙符合犯罪集团特征的，以犯罪集团认定。否则，以一般共同犯罪论。
- 聚众性犯罪一般属于一般共同犯罪。
- 黑社会性质的犯罪组织是特殊的犯罪集团
- 扫黑除恶、《反有组织犯罪法》与有组织犯罪、恶势力组织

7.1.4 共同犯罪人的种类及其责任

1. 主犯及其刑事责任

- 主犯：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。
 - (a) 犯罪集团的首要分子；
 - (b) 聚众性的首要分子；
 - (c) 其他在犯罪集团或一般共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。
- 处罚原则：对犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部犯罪处罚；对其他主犯，按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

2. 从犯及其刑事责任

- 从犯：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子。
- 起次要作用的从犯（次要的实行犯）。
- 起辅助作用的从犯（帮助犯）。
- 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

3. 胁从犯及其刑事责任

- 胁从犯：被胁迫参与共同犯罪的犯罪分子。
- 对于胁从犯，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。
- 胁从犯虽然被胁迫，但尚未丧失意志自由。

4. 教唆犯及其刑事责任

- 教唆犯：以劝说、利诱、授意、怂恿、收买、威胁以及其他方法，将自己的犯罪意图灌输给本来没有犯意或者虽有犯意但犯意不确定的人，使其决意实施犯罪的人。
- 对于教唆犯，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。
- 教唆不满 18 周岁的人犯罪的，应当从重处罚。
- 如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。

教唆未遂的可罚性

- 甲教唆乙实施盗窃以报复丙，乙却强奸了丙，甲构成教唆未遂。
- 甲教唆乙杀害丙，乙仅伤害丙的，甲教唆未遂。
- 甲教唆乙伤害丙，乙却杀害了丙的，甲教唆既遂。
- 甲教唆乙轻伤丙，乙却重伤丙，或者甲教唆乙重伤或者致残丙，乙却仅轻伤丙的，甲教唆既遂。
- 甲为报复乙，雇佣丙“收拾”乙，但未明示“收拾”内容，丙接受雇佣后伤害乙的，甲教唆既遂。

7.2 犯罪停止形态

- 犯罪停止形态 = 犯罪完成形态（完成罪） + 犯罪未完成形态（未完成罪）。
- 既遂是犯罪完成形态，行为完全符合构成要件。

- 预备、未遂和中止是犯罪未完成形态，尚未完全具备构成要件。
- 犯罪既遂是刑罚处罚基准，预备、未遂与中止是刑罚处罚扩张事由。

7.2.1 犯罪既遂

犯罪既遂的界定标准——构成要件说

- 犯罪既遂：具备特定犯罪全部构成要件所呈现的停止形态。
- 判断既遂、未遂的标准：实行行为是否符合特定犯罪的全部构成要件。

犯罪既遂形态

- 结果犯的既遂：以法定的危害结果实际发生为界定标准
- 危险犯的既遂：以法定的危害结果发生的危险状态的出现为为界定标准。
- 行为犯的既遂：以法定的实行行为完成为界定标准；
- 举动犯的既遂：实行行为一经着手，不论是否完成，均告既遂。

本人的见解：

- 犯罪既遂形态的分类取决于不法论立场
- 根据行为无价值论，犯罪分为结果犯与行为犯；
- 根据结果无价值或二元论，犯罪分为实害犯与危险犯。

危险犯与风险社会的刑法干预早期化

危险犯 = 具体危险犯 + 抽象危险犯

1. 具体危险犯：危险状态作为构成要件要素而规定于刑法条款中，法官必须就具体案情审酌判断，认定构成要件所保护的法益确实存在具体危险时，才能成立犯罪。
 - 破坏交通工具罪（116条）：“破坏火车、汽车、电车、船只、航空器，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。”
2. 抽象危险犯：符合构成要件所预定之抽象危险即成立犯罪的危险犯。

- 危险驾驶罪（133 条之一）：“在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；……”
- 规范特征：危险不是该构成要件要素，而是该行为可罚的实质违法的根据；
- 机能特征：立法初衷是立法者用以确认某种制度、规范（高空抛物罪），或者保护某种重大法益（危险驾驶罪）。
- 机制特征：抽象危险犯之危险，是一种立法推定的危险，免除控方对危险的证明责任。
- 推定与反证：抽象危险作为推定而非拟制的危险，可以被反驳。

7.2.2 犯罪预备

- 【第 22 条】：“为了犯罪，准备工具，创造条件的，是犯罪预备。”
- 预备行为形态：准备工具、创造条件
- 犯罪预备行为与犯罪预备形态
- 预备犯可罚性之实质——刑罚处罚的前置
- 预备犯立法取舍之原理——辅助性法益保护与有效保护法益之拉锯
- 预备犯立法设置之原则——普遍处罚原则与例外处罚原则
- 预备犯立法模式之选择——形式预备犯与实质预备犯
- 实质预备犯与帮信罪对处罚范围的扩张

预备犯普遍处罚原则之中国表述

- 刑法总则规定预备犯具有普遍的可罚性，而非仅在刑法分则中例外规定。
- 第 22 条第 2 款：对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

7.2.3 犯罪未遂

刑法第 23 条第 1 款：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。”

犯罪未遂的特征：

1. 已经着手实行犯罪

- 已经开始实施刑法分则规定的客观构成要件行为。——区分犯罪未遂和犯罪预备的基本标志。
- “着手的认定”根本无解？
 - A 出于谋杀的意图向 B 寄送毒药，是杀人的着手而非预备？（寄送主义）。
 - A 出于谋杀的意图向 B 寄送毒药，只是杀人的预备，被害人收到毒药、开始使用毒药之时，才是杀人的着手？（到达主义）
 - 保险诈骗罪的着手？开枪杀人的着手？

2. 犯罪未得逞

- 着手实行后的行为没有完全符合客观构成要件。——区分犯罪未遂和犯罪既遂的关键。
- 盗窃罪的未得逞与得逞的判断：控制说、失控说、失控说或控制说、失控加控制说？

3. 犯罪未得逞是由于犯罪分子意志以外的原因

- ——犯罪未遂区别于犯罪中止的基本标志
- 意志以外的原因的界定
 - 定性界定——违背行为人主观愿望和意图的主客观原因。
 - 定量界定——足以阻止其继续实施并完成犯罪的意志以外的原因。
- 意志以外的原因的种类
 - 行为人以外的客观原因。
 - 行为人自身的客观原因。
 - 行为人主观认识错误。

犯罪未遂的分类：

1. 实行终了的未遂与未实行终了的未遂

- 根据犯罪行为是否实行终了

2. 能犯未遂和不能犯未遂

- 根据犯罪行为实际能否达到既遂
- 不能犯未遂 = 工具不能犯未遂和对象不能犯未遂

工具不能犯未遂

行为人由于认识错误而使用按其客观性质不能实现犯罪意图、不能达到既遂状态的犯罪工具的犯罪未遂形态。

- 砒霜案：甲误把白糖当做砒霜投毒杀人。
- 空枪案：乙误认为枪中有子弹而用以射击。
- 硫磺案：丙出于杀人的意图而让人服用以科学的观点只能致人伤害不能致人死亡的硫磺，监管普通人可能认为硫磺可能致人死亡。
- 空气案：向人体内注射未达致死量的空气。

行为不能犯未遂

行为人由于认识错误而针对本不存在的犯罪对象实施了犯罪行为，因而未能达到既遂状态的犯罪未遂形态。

- 尸体案：甲不知对方已经死亡而向其射击。
- 空口袋案：乙不知对方身无分文而扒窃。
- 空床案：丙向被害人通常就寝的床上射击，恰巧被害人有事外出而幸免于难。
- 假毒品案：丁误把面粉当毒品而予以运输。

绝对不能犯未遂与相对不能犯未遂

- 相对不能犯具有可罚性，但非必须处罚。
- 绝对不能犯——实行行为客观上完全缺乏危险性，行为人基于重大无知而误认可能既遂，而事实上绝对无法实现构成要件。
- 绝对不能犯——迷信犯 + 其他绝对不能犯未遂。
- 迷信犯——行为人基于迷信，企图以灵异施巫术、念咒语等灵异、超自然的手段实现构成要件。

不能犯的可罚性

- 不能犯的可罚性问题，被公认为检验未遂犯处罚根据理论的试金石。
- 区分可罚的不能犯未遂与不可罚的不能犯！
- 以具体危险说为标准进行的区分！
- 具体危险说既符合现代刑法的机能定位（法益保护、行为规训、风险控制等）与规范属性（裁判规范与行为规范），亦符合社会生活通念，能够为社会一般人所接受，更容易被司法实践所接受，并且与世界多数国家的立法、司法与学理的结论基本一致。

【稻草人案】：能犯未遂与不能犯的鉴别

- **【稻草人案 A】** 空旷的田野上，有 1 个稻草人。行为人甲持左轮手枪，误把稻草人当做仇人射击——甲是不可罚的不能犯？
- **【稻草人案 B】** 空旷的田野上，有 6 个稻草人立在一起，B 被迫杀仇人 A 追杀至此。B 临机一动把自己打扮成稻草人，立于稻草人旁，成为第 7 个稻草人。行为人 A 见状依次射击稻草人，但由于只有 6 发子弹，竟让 B 侥幸躲过。——A 成立可罚的不能犯未遂？

犯罪未遂的处罚原则：

- 不减主义：不比照既遂犯从轻、减轻，因为未遂犯的主观恶性和既遂犯并无二致。
- 必减主义：必须比照既遂犯从轻、减轻，因为犯罪未遂形态毕竟没有完成犯罪，并且往往没有实际造成危害结果。
- 得减主义，根据案件的具体情况由法官斟酌裁定是否从轻、减轻处罚。
 - 我国采取得减主义。刑法第 23 条第 2 款规定：“对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。”

7.2.4 犯罪中止

【第 24 条】：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。”

自动放弃犯罪的中止：

- 行为人在犯罪预备或者犯罪实行过程中，自动放弃实施或者继续犯罪，从而使犯罪未完成。

- 前提：在犯罪预备或者犯罪实行过程中放弃犯罪。
 - 既遂以后自动返还原物或者自动赔偿损失的行为，不成立中止。
 - 损害结果修复与犯罪中止？
 - 需罚性与犯罪中止？

自动放弃犯罪的认定：

1. 主观的可能性：必须要求行为人自认为能够继续实施犯罪与完成犯罪。只要行为人主观上认为当时有能力和条件继续实施并完成犯罪，并在此主观认识前提下自动放弃犯罪，不论客观上犯罪是否能够继续实施，均不影响对行为人自动放弃犯罪的认定。
 - “即使我能，我亦不愿”而停止犯罪的，为犯罪中止；
 - “即使我愿，我亦不能”而停止犯罪的，为犯罪未遂。
 - 案例：甲男意图强奸乙女，着手施暴，乙女大声呼救，甲停止施暴——强奸中止还是未遂？
 - 【类型 A】在空旷无人处，无人会听到，甲男在乙女呼救后出于自主的动机而停止施暴的，为中止犯；
 - 【类型 B】甲男在乙女呼救后，因担心路人听到赶来救援，担心罪行败露而停止犯罪，或者因乙女大声呼救而使甲男惊慌失措，致使其失去继续进行性行为可能的，为未遂。
2. 行为的自动性：出于行为人本人的意志而自动放弃犯罪，而不是出于行为人意志以外的主客观原因而被迫停止犯罪。
 - 放弃犯罪的动机不影响犯罪中止的认定：
 - 入室行窃时心想到银行盗窃收获更大而放弃入室盗窃；
 - 行窃时欠缺犯罪勇气以继续实行犯罪而停止犯罪；
 - 为避免前行为被发现而停止现在正在进行的盗窃行为；
 - 从背后施暴攻击身段极具挑逗性的女郎，照了正面发现其极其丑陋而停止强奸；
 - 因被害妇女允诺求奸并约定另行选定时间地点进行，放弃继续施暴；
 - 因受到被害人痛斥而停止强奸；
 - 因被害人的好言相劝或苦苦哀求而停止强奸；
 - 因袭击时才发现被害人是熟人而停止强奸。

3. 中止的彻底性：彻底放弃犯罪。

- 彻底打消继续并完成犯罪的念头，彻底放弃实施自认为可以继续实施并完成的犯罪行为。

自动有效地防止结果发生的中止：

- 实施完毕构成要件行为后、构成要件结果出现前，自动采取措施，有效地避免结果发生。——自动性、有效性

放弃重复侵害行为：

- 实施了足以导致构成要件结果出现的第一次侵害行为，由于意志以外的原因没有得逞，在能够重复实施同一性质的行为并造成预期结果的情况下，自动放弃继续实施行为，因而使犯罪未完成。

- **【典型事态】**

- 甲持枪射杀乙，第一枪未击中时主动放弃继续射击
- 丙持刀砍杀丁，第一刀未砍死时主动放弃继续砍杀

- **【定性争议】**

- 犯罪未遂论——中国过去的判例与理论通说
- 犯罪中止论——近来中国的学界通说

犯罪中止的刑罚优惠——为什么要给予刑罚优惠？

- 刑事政策理论（黄金桥理论）：刑罚优惠为行为人之退却搭建一座黄金桥，使行为人能够迷途知返。
- 奖赏理论：刑法对于迷途知返的行为人的中止行为，应予以奖励。
- 刑罚目的理论：刑法就刑罚目的论的考量，对于中止行为规定减免其刑。
- 并合说：刑罚优惠根据在于违法性与责任的减少、行为人缺乏特殊预防的必要性。

如何给予刑罚优惠？

- 无罪处理
- 不罚处理
- 折中处理

【第 24 条第 2 款】“对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。”

7.3 罪数与竞合

7.3.1 典型的一罪与数罪

1. 一罪与数罪的区分
 - 以行为独立符合构成要件的个数为判断基准
2. 典型的一罪
 - 纯正的一罪
 - 选择的一罪
3. 典型的数罪
 - 同种数罪（处断一罪）
 - 异种犯罪（数罪并罚）

7.3.2 罪数不典型与竞合

1. 想象竞合犯：实质的一罪与想象的数罪
2. 法条竞合犯：实质的一罪与法条的竞合关系
3. 牵连犯：实质的数罪与犯罪的牵连关系
4. 吸收犯：实质的数罪与犯罪的吸收关系
5. 转化犯：实质的数罪与犯行的转化
6. 结合犯：实质的数罪与法定的一罪

第 8 章

侵犯国家法益的犯罪

8.1 国家法益概论

国家法益：宪法确认的作为守护国民相互依存、共同生活的政治组织即“国家”的法益。

- 国家法益包括国家的存立与国家职能
- 国家法益的内涵由国家的体制与性质决定

国家法益对个人法益、社会法益的确认与背离

- 君主制、寡头集权国家：国家法益与个人法益、社会法益的内在紧张性；
- 民主制、人民主权国家：国家法益与个人法益、社会法益的基本一致性

国家法益与个人法益、社会法益类型区分的相对性

- 破坏市场经济秩序罪侵犯国家对市场经济秩序的管理职能？
- 妨害社会管理秩序罪侵犯国家对社会生活秩序的管理职能？
- 渎职罪仅仅侵犯国家职能，抑或往往侵犯社会法益、个人法益？
- 贿赂犯罪仅仅侵犯公职人员职务行为的不可收买（交易）性？

侵犯国家法益的犯罪往往兼具侵犯社会法益或个人法益的性质。

侵犯国家法益犯罪的类型

- 危害国家存立的犯罪：危害国家安全罪、危害国防利益罪、军人违反职责罪
 - 【背叛国家罪】第一百零二条勾结外国，危害中华人民共和国的主权、领土完整和安全的，处无期徒刑或者十年以上有期徒刑。……
 - 【阻碍军人执行职务罪】第三百六十八条以暴力、威胁方法阻碍军人依

法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。

—【军人违反职责罪】第四百二十条军人违反职责，危害国家军事利益，依照法律应当受刑罚处罚的行为，是军人违反职责罪。

• 妨害国家职能的犯罪：贪污贿赂罪、渎职罪

—【贪污罪】第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。……

—【滥用职权罪；玩忽职守罪】第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。……

8.2 危害国家安全罪

8.2.1 “总体国家安全观”下国家安全法益的内涵

《国家安全法》：

- 国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态，以及保障持续安全状态的能力。——第 2 条
- 国家安全工作应当坚持总体国家安全观，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，维护各领域国家安全，构建国家安全体系，走中国特色国家安全道路。——第 3 条

- 国体与政体的安全（人民民主专政的社会主义国家与人民代表大会制度）
- 主权的独立（独立自主地处理内外事务、管理国家的权力，对内统治权与对外独立权，主权与治权的统一与分离）
- 领土的统一（国家主权行使的对象与基础，不可蚕食、不可分裂、不可侵入）

国家安全刑法内涵的相对性和特定性

国家安全刑法内涵的政治性和法律性

从反革命罪到危害国家安全罪——从政治话语逻辑向法律话语逻辑的转型

8.2.2 危害国家安全罪的类型

中国刑法第 102 至 112 条

- 危害国家、颠覆政权的犯罪：背叛国家罪、分裂国家罪、煽动分裂国家罪、武装叛乱、暴乱罪、颠覆政权罪、煽动颠覆国家政权罪、资助危害国家安全犯罪活动罪
- 叛变、叛逃的犯罪：投敌叛变罪、叛逃罪
- 间谍、资敌的犯罪：间谍罪、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪、资敌罪

8.2.3 危害国家安全罪的特点

1. 侵犯法益的重大性

- 国家存立意义上的国家安全是最为重要、核心的国家法益。

2. 法益重大性决定刑法干预的早期化

- 预备行为正犯化：勾结外国、策划分裂国家、策划武装叛乱、暴乱、策划颠覆国家政权
- 组织行为正犯化：组织分裂国家、组织武装叛乱、组织颠覆国家政权
- 教唆行为正犯化：煽动分裂国家、煽动颠覆国家政权
- 帮助行为正犯化：资助危害国家安全犯罪活动罪、资敌罪

3. 法益重大性决定既遂标准降低

- 危害国家安全罪以抽象危险犯为基本立法模式，以实害犯为例外立法模式

4. 法益重大性决定刑法评价的严厉性

- 危害国家安全罪是性质最严重的犯罪，刑法评价与刑罚制裁最为严厉（7 个死刑罪名）

5. 法益重大性决定刑法适用的政治敏感性

- 关乎国家存立，反革命罪的历史表述凸显其政治敏感性。
- 危害国家安全罪不是政治犯，但是否能够引渡取决于被请求国。

6. 法益内涵抽象性、构成要件的概括性决定刑法适用的相对不确定性

- 预备行为的实行化关乎国民行为自由，共犯行为正犯化更关乎国民言论自由。
- 维护国家安全与保障国民自由的平衡，成为危害国家安全罪认定的关键。

8.3 妨害国家职能之贪污贿赂罪

8.3.1 贪腐案件特点

- 长期化，带病提拔司空见惯
- 常态化，腐败成为生活方式
- 巨额化，涉案金额几何级增长
- 潜规则化，潜规则盛行，显规则失灵
- 新型化，规避法律，花样翻新
- 期权化，公权变当期权，约定贿赂、代持贿款
- 群体化，窝案、串案频发
- 黑恶化，官员充当保护伞，黑恶势力漂白染红。

反腐方略

- 从严治党，高压反腐，对腐败零容忍（八项规定、反四风；整治微腐败、防微杜渐，严肃纪律；打虎拍蝇猎狐）；
- 标本兼治，既严惩贪腐又注重机制建设（把权力关进笼子里、不敢腐、不能腐、不想腐；组建监察委、整合反腐力量）；
- 依法反腐，推进反腐制度化与法治化（党要管党，理顺党纪与国法的关系；修订廉洁自律准则与纪律处分条例；完善刑法规定，出台司法解释）。

8.3.2 贪污贿赂罪的种类

1. 【贪污罪】（刑法第 382 条）

- 国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
- 受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。
- 与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。

2. 【私分国有资产罪】（第 396 条）

- 国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

3. 【私分罚没财物罪】（第 396 条第 2 款）

- 司法机关、行政执法机关违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义集体私分给个人，数额较大的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

4. 挪用公款罪（刑法第 384 条）

- 国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
- 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

5. 【受贿罪】（第 385 条）

- 国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
- 对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第 383 条的规定处罚。索贿的从重处罚。

6. 【国有单位受贿罪】（第 387 条）

- 国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
- 前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。

7. 【利用影响力受贿罪】（第 388 条第 2 款）

- 国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
- 离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的，依照前款的规定定罪处罚。

8. 【行贿罪】（第 389 条）

- 为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
- 在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
- 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

9. 对有影响力的人行贿罪（修九第 46 条增设、390 条之 1）

- 为谋取不正当利益，向国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，或者向离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人行贿的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处七年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
- 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

10. 【对单位行贿罪】（第 391 条）

- 为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
- 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

11. 【介绍贿赂罪】（第 392 条）

- 向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
- 介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。

12. 【单位行贿罪】（第 393 条）

- 单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。

13. 【巨额财产来源不明罪】（第 395 条）

- 国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。

14. 【隐瞒境外存款罪】（第 395 条第 2 款）

- 国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。

8.3.3 受贿罪的构成要件

【第 385 条】国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。

1. 贿赂标的：财物、财产性利益、非财产性利益（性贿赂）？

- 【司法解释】贿赂犯罪中的“财物”，包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。后者的犯罪数额，以实际支付或者应当支付的数额计算。

2. 行为：利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益。

- 利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益。
 - 直接利用本人职务上主管、负责、承办某项公共事务的职权；
 - 间接利用职务上有直接隶属、制约关系的其他国家工作人员的职权。
 - 担任单位领导职务的国家工作人员通过不属自己主管的下级部门的国家工作人员的职务为他人谋取利益。
- 基本行为方式
 - 索取他人财物：索取包括索要与勒索。勒索财物不构成敲诈勒索罪。
 - 非法收受他人财物，为他人谋取利益。
- 非典型受贿行为方式
 - 收受回扣、手续费归个人所有。
 - * 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，在帐外私自收受回扣、手续费，归个人所有的，应当以受贿论处。
 - 斡旋受贿
 - * 国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的行为。

3. 主体：国家工作人员

- 主体不包括受委托管理经营国有财产的人员。
- 注意与非国家工作人员受贿罪区分！

4. 主观构成要件要素——受贿故意

- 先收受他人财物后为他人谋取利益；
- 收受他人财物与为他人谋取利益同时进行；
- 先为他人谋取利益后收受他人财物？

5. 罪量

- 刑法第 383 条：受贿数额较大或者有其他较重情节的，构成受贿罪。
- 2016 司法解释：数额较大：3 万元以上 20 万元以下；情节较重：1 万以上不满 3 万，具有解释列举的 8 种情形之一。

问题之一：替人办事后收人钱财可否认定受贿故意？

- 只要认识到他人交付财物是对自己职务行为的不当报酬而予以收受，就具有受贿故意。

问题之二：事后受贿如何认定？

- 国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，并与请托人事先约定，在其离退休后收受请托人财物，构成犯罪的，以受贿罪定罪处罚。

问题之三：受贿后用于公务支出如何认定？

- 国家工作人员出于贪污、受贿的故意，非法占有公共财物、收受他人财物之后，将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的，不影响贪污罪、受贿罪的认定，但量刑时可以酌情考虑。

问题之四：事后知情如何认定？

- 特定关系人索取、收受他人财物，国家工作人员知道后未退还或者上交的，应当认定国家工作人员具有受贿故意。

问题之五：收受财物后退还或上交如何处理？

- 国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿。国家工作人员受贿后，因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。

8.3.4 贪污罪、受贿罪的量刑标准

刑法第 383 条：对犯贪污罪、受贿罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：

（一）数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

（二）数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

（三）数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

- 犯贪污、受贿罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
- 贪污、受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民

利益造成特别重大损失的，可以判处死刑。

- 符合前款规定的情形，但具有自首，立功，如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，或者避免、减少损害结果的发生等情节，不是必须立即执行的，可以判处死刑缓期二年执行。
- 符合第一款规定情形的，根据犯罪情节等情况可以判处死刑缓期二年执行，同时裁判决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

贪污受贿定罪量刑标准调整的根据

- 党纪严于国法：党纪挺在前面，对腐败零容忍应当考虑党纪政纪对轻微贪腐行为的处分；
- 尊重中国改革与发展事实上是以高腐败成本为代价的历史与现实。——历史唯物主义与辩证唯物主义；
- 考虑腐败严重的官场生态，标准过低带来的政治后果。
- 确定数额的根据应当考虑实际购买力水平的变化；
- 数额作为定罪量刑的标准具有相对性，不能以数额作为绝对排他的标准；

8.4 妨害国家职能之渎职罪

8.4.1 类型

- 刑法第 397 条至 419 条规定 36 种渎职罪。
- 根据行为表现分为滥用职权型渎职罪与玩忽职守型渎职罪；
- 依据行为主体分为一般国家机关工作人员的渎职罪、司法工作人员的渎职罪与特定机关工作人员的渎职罪。个别罪名为一般主体。
- 397 条是渎职罪的一般规定，398 以后各条是渎职罪的特别规定，是一般法与特别法的法条竞合。

8.4.2 基本问题

1. 法益

- 职务行为的公正性与勤勉性，是公职人员对于国家应当履行的积极义务。

- 职务行为的不可肥私性与不可交易性，是国家公职人员对于国家承担的消极义务。
- 贪污贿赂罪违反消极义务，侵犯职务行为的不可肥私性或不可交易性。
- 渎职罪违反积极义务，侵犯职务行为的公正性或勤勉性？

2. 行为

- 违法行使权力的四种形式：
 - 超越职务权限范围行使权力；
 - 未遵循公职的设立宗旨，按法定或规定的要求行使权力；
 - 未基于服务公共利益的动机而行使权力；
 - 任意放弃职权的行使。
- 渎职行为方式：作为 + 不作为。
- 法定行为类型：滥用职权 + 玩忽职守。

3. 结果

- 多数渎职罪系结果犯，要求“造成重大损失”，旨在限缩处罚范围。
- “重大损失”：既包括人员伤亡与财产损失等直观的损害后果，也包括“恶劣的社会影响”等抽象损害后果；既包括直接造成的损害后果，也包括间接引起的损害后果。
- 少数渎职罪系情节犯，危害结果是判断情节是否严重的因素之一，但非必要要素。
- 法定结果或情节是否存在，是区分罪与非罪的标志，而不是既遂未遂的界限。

4. 因果关系与客观归责

- 渎职罪违反公正且勤勉地行使权力的积极义务。
- 义务犯的判断，重要的并不在于违反义务的行为是否操控了因果流程，是否为结果的出现提供了现实的作用力，而在于导致结果现实化的危险，是否处于行为人需要承担的义务范围之内。
- 渎职结果归责的判断，不取决于渎职行为是否操控了导致重大损失出现的因果流程，而取决于渎职行为内含的风险是否已经实现，具体的因果流程如何对于结果归责的认定没有影响，充其量只是影响对行为人的量刑。

5. 主体

- 渎职罪的主体限于国家机关工作人员。
- **【立法解释】**：在依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员，或者在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员，或者虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，在代表国家机关行使职权时，有渎职行为，构成犯罪的，依照刑法关于渎职罪的规定追究刑事责任。

6. 主观构成要件（罪责）

- 故意犯罪？
- 过失犯？
- 故意或过失犯罪？
- 复合罪过？
- 模糊罪过？

第 9 章

侵犯社会法益的犯罪

9.1 危害公共安全罪

9.1.1 公共安全的界定

- 不特定或者多数人的生命、健康或者财产的安全
- 公共安全：社会法益、超个人法益

9.1.2 种类

以危险方法危害公共安全的犯罪

放火罪、失火罪、决水罪、过失决水罪、爆炸罪、过失爆炸罪、投放危险物质罪、过失投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪、过失以危险方法危害公共安全罪

主要问题：

- 实害犯与（具体）危险犯
- 故意犯与过失犯
- 明示列举与概括兜底（其他危险方法的相当性判断）
- 普通规定与特别规定的竞合（第 114、115 条与其他条文）

破坏特定对象的犯罪

- 破坏交通工具罪与过失破坏交通工具罪
- 破坏交通设施罪与过失破坏交通设施罪
- 破坏电力设备罪与过失破坏电力设备罪
- 破坏易燃易爆设备罪与过失损坏易燃易爆设备罪

- 破坏广播电视设施、公用电信设施罪与过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪

特别问题：本类犯罪既遂、中止的判断

恐怖主义、极端主义犯罪

- 组织、领导、参加恐怖组织罪、帮助恐怖活动罪、准备实施恐怖活动罪
- 宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪与利用极端主义破坏法律实施罪
- 强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志罪、非法持有宣扬恐怖主义、极端主义的物品罪
- 劫持航空器罪与劫持船只、汽车罪
- 暴力危及飞行安全罪

主要问题

- 犯罪组织犯罪化
- 共犯行为正犯化
- 预备行为实行化
- 特定言论犯罪化
- 刻意设置口袋罪
- 特定生活方式犯罪化?
- 持有型犯罪作为堵截构成要件
- 劫持交通工具犯罪的犯罪形态：既遂与未遂
- 暴力危及飞行安全罪：具体危险犯抑或（具体）抽象危险犯?

针对枪支、弹药、爆炸物、危险物质、危险物品的犯罪

非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪、非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪、违规制造、销售枪支罪、盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪、抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪、非法持有、私藏枪支、弹药罪、非法出租、出借枪支罪、丢失枪支不报罪、非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪

主要问题：

- 严格管控与确保绝对安全
- 枪支的界定：仿真枪、气枪是玩具还是枪？行政裁量标准与司法裁判标准？
- 对是否枪支的事实认识错误与对涉枪行为违法性的认识错误

责任事故犯罪

重大飞行事故罪、铁路运营安全事故罪、交通肇事罪、危险驾驶罪、重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪、重大劳动安全事故罪、大型群众性活动重大安全事故罪、危险物品肇事罪、工程重大安全事故罪、教育设施重大安全事故罪、消防责任事故罪、不报、谎报安全事故罪

主要问题：

- 过失犯为主，故意犯为例外
- 实害犯为主，危险犯为例外
- 因果关系与客观归责

9.2 破坏经济秩序罪

破坏国家市场监管制度与市场经济秩序，妨碍市场机制与市场功能正常运作，损害公共利益以及其他市场主体与消费者合法权益的行为。

经济犯罪（秩序犯）= 财产犯罪（财产犯）？

贪污贿赂犯罪 = 经济犯罪（秩序犯）？

9.2.1 基本犯罪

- 生产、销售伪劣商品罪
- 走私罪
- 妨害对公司、企业的管理秩序罪
- 破坏金融管理秩序罪
- 金融诈骗罪
- 危害税收征管罪
- 侵犯知识产权罪
- 扰乱市场秩序罪

9.2.2 重点犯罪

生产、销售伪劣产品罪

生产、销售伪劣产品罪，是指生产者、销售者违反国家产品质量管理法规，在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额在50000元以上或者具有其他严重情节的行为。

法条竞合：刑法第141至148条规定的生产、销售伪劣产品犯罪各有其特定的犯罪对象，属于特别法。第140条规定的生产、销售伪劣产品罪的犯罪对象则是普通伪劣产品，属于一般法。

刑法第149条的特别规定

- 想象竞合：实施生产、销售伪劣商品犯罪，同时构成侵犯知识产权、非法经营等其他犯罪的，属于想象竞合犯，依照处罚较重的规定定罪处罚。
- 数罪并罚：实施刑法第140条至第148条规定的犯罪，又以暴力、威胁方法抗拒查处，构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。

走私普通货物、物品罪

走私普通货物、物品罪，是指违反海关法规，逃避海关监管，非法运输、携带或者邮寄国家禁止进出口的物品以外的普通货物、物品进出国（边）境，偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的行为。

伪造货币罪

伪造货币罪：违反国家货币管理法规，仿照货币的图案、形状、色彩、防伪技术等外部特征，非法制造假货币，冒充真货币的行为。

1. 行为对象：本币与外币。伪造已经退出流通或者作废的货币的，不构成犯罪。伪造后又用以骗取他人财物，数额较大的，构成诈骗罪。
2. 行为方式：伪造与变造的区别：“无中生有”与“由少变多”。
3. 使用目的：不成文的超过的主观构成要件要素
4. 罪量：伪造货币的总面额不满2000元或者币量不满200张（枚）的，不构成犯罪。

非法吸收公众存款罪

【第一百七十六条】“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

“有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。”

非吸罪认定的“四性”大法

违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：

- （一）未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金（非法性）
- （二）通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传（公开性）
- （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（利诱性）
- （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。（社会性）

未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

利用未公开信息交易罪（老鼠仓）

利用未公开信息交易罪：证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的行为。

洗钱罪

洗钱罪：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

【第一百九十一条】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

- （一）提供资金帐户的；
- （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
- （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
- （四）跨境转移资产的；
- （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

解释论的争议——自洗钱：不可罚的事后行为？→ 修十一的确认：自洗钱纳入洗钱罪！

集资诈骗罪

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

- **是否具有非法占有目的**，是正确区分非吸罪和集资诈骗罪的关键。
- 司法解释第 4 条
- **【指导性案例】**指导意见：对非法占有目的的认定，应当围绕融资项目真实性、资金去向、归还能力等事实、证据进行综合判断。行为人将所吸收资金大部分未用于生产经营活动，或名义上投入生产经营，但又通过各种方式抽逃转移资金，或供其个人肆意挥霍，归还本息主要通过借新还旧来实现，造成数额巨大的募集资金无法归还的，可以认定具有非法占有的目的。

【被害人自陷风险与自我答责原理】

被害人认识到他人的行为可能损害自己的法益，却参与他人的行为，并且该参与没有消

除，甚至提升他人的行为对自己法益侵害的危险性的，则被害人必须自担风险，对由此产生的法益侵害结果负责，由此导致他人责任的减轻或者免除。

【集资诈骗案的被害人自陷风险与自我答责】

被害人放弃或疏于法益的自我保护：非法集资案件中出资者的行为答责，可能阻却集资者的集资诈骗罪，而仅构成非法吸收公众存款罪。

贷款诈骗罪与骗取贷款罪

- 贷款诈骗罪：以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。
- 骗取贷款罪【第一百七十五条之一第一款】：“以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”

《修十一》修改骗取贷款、票据承兑、金融票证罪入罪门槛规定，对由于“融资门槛高”、“融资难”等原因，民营企业因生产经营需要，在融资过程中虽然有一些违规行为，但并没有诈骗目的，最后未给银行造成重大损失的，不作为犯罪处理。

骗取贷款案件中的被害人自陷风险类型

- 被害人自我创设风险：银行工作人员主动要求借款人提供虚假材料
- 被害人明知有风险而接受风险：银行工作人员默认为借款人提供虚假材料

信用卡诈骗罪

信用卡诈骗罪：以非法占有为目的，通过使用伪造或者作废的信用卡、冒用他人信用卡或者恶意透支的方法进行诈骗，数额较大的行为。

“信用卡”：由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。

行为方式：

- (1) 使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
- (2) 使用作废的信用卡；
- (3) 冒用他人的信用卡；

(4) 恶意透支。

“恶意透支”的认定

- “恶意透支”：持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。
- 数额较大：数额在五万元以上不满五十万元。
- 银行的两次“有效催收”至少间隔三十日。
- 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法“恶意透支”的规定。

保险诈骗罪

保险诈骗罪：投保人、被保险人或者受益人，以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的办法，进行保险诈骗活动，数额较大的行为。

保险诈骗行为方式：

- (1) 投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的。
- (2) 投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程
度，骗取保险金的。
- (3) 投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金的。
- (4) 投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金的。
- (5) 投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的。

逃税罪

逃税罪：纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，或者扣缴义务人采取采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的行为。

违法阻却（确证）事由

- 纳税人逃税数额较大并且占应纳税额百分之十以上，或者逃税数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任。

- 五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。

假冒注册商标罪

【第二百一十三条】“未经注册商标所有人许可，在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”

【商标法】第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

- （一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；
- （二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。

侵犯著作权罪

- 刑法第 217 条及六种侵权行为方式
- 《著作权法》对著作权的界定
- 著作权：包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、使用权和获得报酬权在内的人身权和财产权；
- 与著作权有关的权利：包括出版者权、表演者权、录音录像制作者权、广播电台、电视播放权在内的邻接权）。

侵犯商业秘密罪

- 刑法第 219 条：
- **【反不正当竞争法】**第 9 条对商业秘密的界定：
- 本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

排除犯罪事由（违法阻却事由）

法定正当合理适用 = 阻却违法事由甚或容许构成要件

- 《商标法》第五十九条规定的商标描述性使用、在先使用；
- 《著作权法》第二十四条规定的合理使用；
- 第二十五条、第三十五条第二款、第四十二条第二款、第四十六条第二款规定的法定许可使用；
- 《著作权法》第 50 条的避开技术措施的法定许可
- 《专利法》第六十七条规定的现有技术
- 《专利法》第七十五条规定的专利先用权等正当合理使用。
- 权利人放弃权利
- 涉案作品的著作权或者录音制品的有关权利不受我国著作权法保护
- 权利保护期限届满
- 专利保护豁免
- 2021 年 5 月 21 日世界健康峰会《罗马宣言》与新冠疫苗专利保护豁免、自愿专利授权和技术转让

非法经营罪

非法经营罪，是指违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为。

【《刑法》第二百二十五条】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

- （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
- （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

- (三) 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
- (四) 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

- 口袋罪是否违反罪刑法定原则？
- 口袋罪的构成要件如何解释？
- 法定犯与空白罪状：刑法典中的法定犯必然采取空白罪状的描述方式。
- 违反国家规定作为前置性构成要件要素。

9.3 妨害社会管理秩序罪

妨害社会管理秩序罪的种类

- 扰乱公共秩序罪
- 妨害司法罪
- 妨害国(边)境管理罪
- 妨害文物管理罪
- 危害公共卫生罪
- 破坏环境资源保护罪
- 走私、贩卖、运输、制造毒品罪
- 组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪
- 制作、贩卖、传播淫秽物品罪

9.3.1 《刑法修正案（十一）》的废改立

袭警罪

【第二百七十七条第五款】：“暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。”

评注：将袭警行为从妨害公务罪中独立成罪，加强对警察执法权威与人身安全的刑法保护。

冒名顶替罪

【第二百八十条之二】：“盗用、冒用他人身份，顶替他人取得的高等学历教育入学资格、公务员录用资格、就业安置待遇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

- “组织、指使他人实施前款行为的，依照前款的规定从重处罚。
- “国家工作人员有前两款行为，又构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。”

评注：回应王娜娜、王丽、陈春秀等被冒名顶替入学、入职、就业系列事件引发的公众对社会公平、诚信、机会平等的关注，将侵犯姓名权、受教育权、劳动权等“盗取他人人生”的冒名顶替行为犯罪化。

高空抛物罪

【第二百九十一条之二】：“从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

“有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”

高空抛物入罪与“头顶上的安全”

催收非法债务罪

【第二百九十三条之一】：“有下列情形之一，催收高利放贷等产生的非法债务，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：

- “（一）使用暴力、胁迫方法的；
- “（二）限制他人人身自由或者侵入他人住宅的；
- “（三）恐吓、跟踪、骚扰他人的。”

评注：总结“扫黑除恶”专项斗争实践经验，将采取暴力、“软暴力”等手段催收高利放贷产生的债务以及其他法律不予保护的债务的行为规定为犯罪，维护正常的社会生活与经济交往秩序。

侵害英雄烈士名誉、荣誉罪

【第二百九十九条之一】：“侮辱、诽谤或者以其他方式侵害英雄烈士的名誉、荣誉，损害社会公共利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。”

评注：维护社会主义核心价值观，保护英雄烈士名誉，与英雄烈士保护法相衔接，将侮辱、诽谤英雄烈士的行为明确规定为犯罪。

组织参与国（境）外赌博罪

【第 303 条第 3 款】“组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。”

打击组织中国公民参与国外境外赌博行为，堵塞资金外流通道，防止中国公民被境外机构、人员腐蚀、引诱。

非法采集人类遗传资源、走私人类遗传资源材料罪

【第三百三十四条之一】：“违反国家有关规定，非法采集我国人类遗传资源或者非法运送、邮寄、携带我国人类遗传资源材料出境，危害公众健康或者社会公共利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”

评注：为维护国家安全、生物安全与公众健康，防范生物威胁，与生物安全法衔接，增加本罪。

何为人类遗传资源？人类遗传资源资源 = 人类遗传资源材料和人类遗传资源信息两大类。人类遗传资源材料是指含有人体基因组、基因等遗传物质的器官、组织、细胞等遗传材料；人类遗传资源信息是指利用人类遗传资源材料产生的数据等信息资料。——《遗传资源资源管理条例》

非法植入基因编辑、克隆胚胎罪

【第三百三十六条之一】：“将基因编辑、克隆的人类胚胎植入人体或者动物体内，或者将基因编辑、克隆的动物胚胎植入人体内，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”

评注：回应“贺建奎非法行医案”引发的关注，为维护国家安全和生物安全，防范生物威胁，与生物安全法衔接，增设本罪。

非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物罪

【第三百四十一条第三款】：“违反野生动物保护管理法规，以食用为目的非法猎捕、收购、运输、出售第一款规定以外的在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物，情节严重的，依照前款的规定处罚。”

评注：将以食用为目的非法猎捕、收购、运输、出售除珍贵、濒危野生动物和“三有野生动物”以外的陆生野生动物，情节严重的行为规定为犯罪，从源头上防范和控制重大公共卫生安全风险。

破坏自然保护地罪

【第三百四十二条之一】：“违反自然保护地管理法规，在国家公园、国家级自然保护区进行开垦、开发活动或者修建建筑物，造成严重后果或者有其他恶劣情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

“有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”

评注：回应公众与高层对诸如“秦岭自然生态破坏案”等破坏自然保护地案件的关注，将严重破坏自然保护区生态环境资源的行为规定为犯罪。

非法引进、释放、丢弃外来入侵物种罪

【第三百四十四条之一】：“违反国家规定，非法引进、释放或者丢弃外来入侵物种，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”

评注：为维护国家安全和生物安全，防范外来入侵物种威胁，与生物安全法衔接，增设本罪。

妨害兴奋剂管理罪

【第三百五十五条之一】：“引诱、教唆、欺骗运动员使用兴奋剂参加国内、国际重大体育竞赛，或者明知运动员参加上述竞赛而向其提供兴奋剂，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

“组织、强迫运动员使用兴奋剂参加国内、国际重大体育竞赛的，依照前款的规定从重处罚。”

评注：为维护公平竞赛与运动员身体健康，特别是为 2022 年冬奥会营造良好体育法治环境，增设本罪。

调整妨害传染病防治罪构成要件

“违反传染病防治法的规定，有下列情形之一，引起甲类传染病以及依法确定采取甲类传染病预防、控制措施的传染病传播或者有传播严重危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑：

- （一）供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准的；
- （二）拒绝按照疾病预防控制机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的污水、污物、场所和物品进行消毒处理的；
- （三）准许或者纵容传染病病人、病原携带者和疑似传染病病人从事国务院卫生行政部门规定禁止从事的易使该传染病扩散的工作的；
- （四）出售、运输疫区中被传染病病原体污染或者可能被传染病病原体污染的物品，未进行消毒处理的；
- （五）拒绝执行县级以上人民政府、疾病预防控制机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施的。

评注：为保护公共卫生安全，总结新冠肺炎疫情防控经验和需要，与传染病防治法等相衔接明确新冠肺炎等依法确定的采取甲类传染病管理措施的传染病，属于本罪调整范围，增加本罪的行为类型。

9.3.2 网络犯罪

- 非法侵入计算机信息系统罪（285 条）
- 破坏计算机信息系统罪（286 条）
- 利用计算机实施传统犯罪的注意规定（第 287 条）
- 非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪（285 条第 2 款）
- 提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪（第 285 条第 3 款）
- 拒不履行网络安全管理义务罪（第 286 条之一，纯正义务犯）
- 增设准备网络违法犯罪活动罪（第二百八十七条之一，预备行为实行化）
- 帮助网络犯罪活动罪（第二百八十七条之二，帮助行为正犯化）
- 编造、故意传播虚假信息罪（第二百九十一条之一第二款网络空间作为犯罪场域的制谣、传谣犯罪化）
- 增设刑法第 285、286 条单位犯罪（互联网产业化时代强化对单位犯罪的归责）
- 增设网络侮辱诽谤的诉讼救济（第二百四十六条第三款，自诉案件的公权力支持）

9.3.3 黑恶犯罪

- 黑恶势力坐大路线图：一般共同犯罪——恶势力结伙犯罪——恶势力集团犯罪——黑社会性质组织犯罪——黑社会犯罪组织。
- 20 世纪 90 年代起，黑恶势力逐渐坐大，出现了黑社会性质的犯罪组织。
- 严禁黑恶势力发展坐大，严防境外黑社会组织在境内立足扎根。
- 既要打早打小，又要打准打实，既不“拔高”也不“降格”！如何可能？！
- 从 2000 年 12 月到 2001 年 10 月，第一次全国范围打黑除恶专项斗争。
- 2006 年 2 月至 2007 年 1 月，第二次全国开展打黑除恶专项斗争，
- 2018 年 1 月至 2020 年 12 月，第三次全国“扫黑除恶”专项斗争。

9.3.4 污染环境罪

第 338 条：违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

- 先污染后治理——无法摆脱的魔咒？
- 环境生态危机与环境法益的刑法保护
- 兰草案、鹦鹉案、马戏团案等热点案件折射的行政犯司法思维混乱

9.3.5 走私、贩卖、运输、制造毒品罪

- 第 347 条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
- 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
 - （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
 - （二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
 - （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
 - （四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；

—（五）参与有组织的国际贩毒活动的。

- 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
- 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
- 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
- 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
- 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。

对象

刑法第 157 条：毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。

- 毒品是法律概念，精神药品和麻醉药品是医学概念，精神药品和麻醉药品被纳入国家管制且脱离医学、生产、生活目的滥用时，即为毒品。
- 笑气是毒品吗？

行为

- 走私毒品：
- 贩卖毒品：明知是毒品而非法销售或者以贩卖为目的而非法收买毒品
- 运输毒品：明知是毒品而非法运送毒品的行为。
- 制造毒品：非法利用毒品原植物直接提炼或者用化学方法加工、配制毒品，或者以改变毒品成分和效用为目的，用混合等物理方法加工、配制毒品。

主观构成要件

- 明知是毒品而走私、贩卖、运输、制造，但不要求行为人对毒品的种类、名称、化学成分和效用有确定认识。
- 《昆明会议纪要》：具有下列情形之一，被告人不能作出合理解释的，可以认定其明知走私、贩卖、运输、非法持有的是毒品，但有证据证明其确实不知情或者确系被蒙骗的除外：（1）执法人员在口岸、机场、车站、港口、邮局、快递站点等场所检查时，要求申报为他人运输、携带、寄递的物品和其他毒品疑似物，并告知法律责任，但被告人未如实申报，在其运输、携带、寄递的物品中查获毒品的；（2）以伪报、藏匿、伪装等蒙蔽手段逃避海关、边防等检查，或者行程路线故意绕开检查站点，在其运输、携带、寄递的物品中查获毒品的；（3）在执法人员检查时有逃跑、藏匿、丢弃、试图销毁其携带的物品、弃车逃离或者其他逃避、抗拒检查行为，在其携带的物品或者遗弃的车辆中查获毒品的；（4）采用高度隐蔽方式运输、携带、交接物品，明显违背合法物品的惯常运输、携带、交接方式，从中查获毒品的；（5）以虚假的身份、地址或者物品名称办理托运、寄递手续，从托运、寄递的物品中查获毒品的；（6）采用隐匿真实身份、支付不等值报酬等不合理方式，指使、雇用他人运输、携带、寄递物品或者代为接收物流寄递的物品，从中查获毒品的；（7）为获取不同寻常的高额、不等值报酬，为他人运输、携带、寄递物品或者接收物流寄递的物品，从中查获毒品的；（8）其他可以认定被告人明知的情形。

第 10 章

侵犯个人法益的犯罪

10.1 故意杀人罪

10.2 故意伤害罪

10.3 侵犯自由的犯罪

10.3.1 非法拘禁罪

10.3.2 绑架罪

10.3.3 拐卖妇女儿童罪

【法条规定】第二百四十条拐卖妇女、儿童罪

拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：

- （一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子；
- （二）拐卖妇女、儿童三人以上的；
- （三）奸淫被拐卖的妇女的；
- （四）诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；
- （五）以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；
- （六）以出卖为目的，偷盗婴幼儿的；
- （七）造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；

- (八) 将妇女、儿童卖往境外的。拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。

法益

- 买卖人口犯罪的保护法益不是被买卖的特定被害人之人身自由、安全、自我决定权等个人人身法益，而是直接被买卖之特定被害人与间接被冒犯的人类全体以人身不可买卖性为核心的人格尊严整体。

对象

妇女、儿童

- 儿童包括亲生子女或收养子女
- 余华英拐卖儿童案
- 拐卖两性人、变性人如何界定？
 - 前者根据主要性征界定，后者根据变性后的性征界定？
- 拐卖 14 周岁以上的男性如何界定？
 - 卖给他人从事强迫劳动的，以强迫劳动罪论处（从共犯到正犯）！

2010 年最高院、最高检、公安部、司法部《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》

17. 要严格区分借送养之名出卖亲生子女与民间送养行为的界限。区分的关键在于行为人是否具有非法获利的目的。应当通过审查将子女“送”人的背景和原因、有无收取钱财及收取钱财的多少、对方是否具有抚养目的及有无抚养能力等事实，综合判断行为人是否具有非法获利的目的。具有下列情形之一的，可以认定属于出卖亲生子女，应当以拐卖妇女、儿童罪论处：

- (1) 将生育作为非法获利手段，生育后即出卖子女的；
- (2) 明知对方不具有抚养目的，或者根本不考虑对方是否具有抚养目的，为收取钱财将子女“送”给他人的；
- (3) 为收取明显不属于“营养费”、“感谢费”的巨额钱财将子女“送”给他人的；
- (4) 其他足以反映行为人具有非法获利目的的“送养”行为的。

行为

拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童。

- 拐骗：采用欺骗、利诱等手段，使妇女儿童上当受骗后将其带走；
- 绑架：以暴力、胁迫等手段，使妇女、儿童脱离原来生活状态，予以实力支配；
- 收买：以转手出卖为目的，以金钱、财物为对价买得妇女儿童。
- 贩卖：出卖妇女、儿童
- 接送：接受、运送他人妇女、儿童
- 中转：为拐卖妇女、儿童提供中转场所或机会。
- 偷盗：偷盗婴幼儿（16 司法解释：诱骗婴幼儿使其脱离监护人、看护人，视为偷盗婴幼儿）

选择性罪名：对象的选择性 + 行为的选择性！

主体

一般主体：父母出卖子女的，监护人出卖被监护人的，护理、医疗、康养或者其他福利机构工作人员出卖被护理人、患者、被扶养人的，构成本罪。

- 医疗机构、社会福利机构等单位的工作人员以非法获利为目的，将所诊疗、护理、抚养的儿童出卖给他人的，以拐卖儿童罪论处。

主观方面处于故意并且具有出卖目的

- 出卖目的是超过的主观要素，目的是否实现，除贩卖外，不影响既遂的判断。
- 出卖目的是否实现，不以是否获利或获利多少为依据。
- 出卖目的可以是以为本人出卖为目的，也可以是为他人出卖为目的；
- 以勒索财物、索取债务为目的或者以结婚、扶养、强迫劳动为目的，实施拐骗、绑架等行为的，不以本罪论。

10.3.4 侵犯自由的其他犯罪

1. 收买被拐卖的妇女、儿童罪
2. 聚众阻碍解救被拐卖的妇女、儿童罪
3. 诬告陷害罪
4. 强迫劳动罪
5. 非法搜查罪
6. 非法侵入住宅罪
7. 拐骗儿童罪
8. 组织残疾人、儿童乞讨罪
9. 组织未成年人进行违反治安管理活动罪

10.4 侵犯性自决的犯罪

10.4.1 强奸罪

法益

- 身体健康（传统见解）
- 性的自我决定权（现在通说）
- 按照自己的意愿自主决定是否与他人、如何与他人、以何种方式、在何时、何地与他人进行性行为的权利。
- 被害人的年龄未达法定同意年龄，推定为没有性自决能力，即使作出同意，与之性交的，亦为（法定）强奸。

行为对象

从妇女到他人

- 已满 14 周岁不满 18 周岁的少女、成年妇女、不满 14 周岁的幼女。
- 妇女限于良家妇女？强奸性工作者？
- 性自主决定权与男人作为强奸对象
- 婚内强奸与妻子作为强奸罪的对象？
- 两性人、变性人能否作为行为对象？

主体

- 行为主体仅限男性?
- 妇女成为作为直接正犯? 妇女作为间接正犯? 妇女作为共同正犯? 妇女作为教唆犯? 妇女作为帮助犯?
- 丈夫作为行为主体? 丈夫冒充陌生人强奸妻子是否成立强奸罪? 肯定论/否定论/区分论
- 已满 14 周岁不满 16 周岁的人可以成为本罪主体。已满 14 周岁不满 16 周岁的人，与幼女发生性关系构成犯罪的，依照刑法第 17 条、第 236 条第 2 款的规定，以强奸罪定罪处罚。
- 偶尔与幼女发生性关系，情节轻微、尚未造成严重后果的，不认为是犯罪。

行为

以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女或者奸淫幼女

1. 手段行为：施暴行强

- 暴力的含义
- 胁迫的含义
- 其他手段的含义
- 手段行为是否必须足以达到使妇女不能反抗、不敢反抗与不知反抗的程度?

2. 目的行为：奸淫妇女

- 奸淫：男女双方生殖器之进入
 - 趋势：以强制性交罪取代强奸罪
 - 奸淫的方式不再限于男女生殖器官的插入
- 同意的性交阻却行为该当强奸罪构成要件
 - 未得对方同意与之性交即该当强奸罪构成要件
 - “违背妇女意志”需要控方证明，“未得对方同意”要求被告证明性交得到对方同意。
 - 从“违背妇女意志”到“未得对方同意”导致犯罪扩大化

- 证明责任转移标志性犯罪立法的严厉化
- 法益内涵变迁即尊重个人性自主、性自决的逻辑展开!

主观故意与奸淫目的

- 行为人在奸淫目的支配下故意以暴力、胁迫或者其他手段强行与妇女进行性交。
- 奸淫目的支配下的手段行为与目的行为的故意
- 误认为对方同意性交，或者误认为对方反抗是为羞涩而强行性交，误以为对方已满 14 周岁，为事实认识错误，阻却强奸故意。
- 事实认识错误成立过失强奸罪？

10.4.2 奸淫幼女（法定强奸）

- 奸淫幼女的特殊性：严格责任？
- 对象的特殊性：幼女
- 行为方式的特殊性：奸淫与强奸？
- 主观故意的特殊性：故意与“明知”

10.4.3 负有特定照护职责人员性侵罪